الروض المربع شرح زاد المستقنع

البهوتي (ت ١٠٥١هـ)

الجزء ٣

نص المؤلف كما في طبعة: الرياض ، 1390 ، مكتبة الرياض الحديثة
المصدر: مجموعة (OpenITI (KITAB، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

كتاب الوصايا

+ جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة

وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت

ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها و (يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير) عرفا (أن يوصي بالخمس) روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ ولا تجوز الوصية (بأكثر من الثلث لأجنبي) لمن له وارث (ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث و الثلث كثير متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوراث في القدر لا في العين والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث (ف) إنها (تصح تنفيذا) لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة (وتكره وصية فقير) عرفا (وارثه محتاج) لأنه عدل عن أقاربه المحاويج

إلى الأجانب (وتجوز) الوصية (بالكل لمن لا وارث له) روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع (وإن لم يف الثلث بالوصايا) أو لم تجز الورثة (فالنقص) على الجميع (بالقسط) فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول (وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث) كأخ حجب بابن تجدد (صحت) الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له (والعكس بالعكس) فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة

(ويعتبر) لملك الموصى له المعين الموصى به (القبول) بالقول أو ما قام مقامه كالهبة (بعد الموت) لأنه وقت ثبوت حقه وهي على التراخي فيصح (وإن طال الزمن) بين القبول والموت و (لا) يصح القبول (قبله) أي قبل

الموت لأنه لم يثبت له حق وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت (ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها (ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها) ولو قبل القبض (لم يصح الرد) لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها (ويجوز الرجوع في الوصية) لقول عمر يغير الرجل ماشاء في وصيته فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع (وإن قال) الموصى (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد (و) إن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) لأنه لما مات قبل قدومه استقرت

له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه (ويخرج) وصي فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة ونذر وكفارة (من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به) لقوله تعالى ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي (فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به) أي بالواجب (فإن بقي منه) أي من الثلث (شيء أخذه صاحب التبرع) لتعيين الموصي (وإلا) يفضل شيء (سقط) التبرع لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال

1 باب الموصى له

+ (تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من مسلم أو كافر لقوله تعالى ﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ﴾

قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده (ولعبده بمشاع كثلث) لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله (ويعتق منه بقدره) أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته (ويأخذ الفاضل) من الثلث لأنه صار حرا وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث (و) إن وصى (بمائة أو) ب (معين) كدار وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده لأنه يصير ملكا للورثة فما وصي له به فهو لهم فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره (وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث (و) تصح أيضا (لحمل تحقيق وجوده قبلها) أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو لاقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة

(وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ) الألف راكبا أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه (ولا تصح) الوصية (لملك) وجني (وبهيمة وميت) كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم (فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي) لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده (وإن جهل) موته (ف) للحي (النصف) من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر ولا

تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها (وإن أوصى بماله لا بنيه وأ جنبي فردا) وصيته (فله التسع) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به

باب الموصى به

+ (تصح) الوصية (بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء) وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى (و) تصح (بالمعدوم ك) وصية ب (ما يحمل حيوانه) وأمته (وشجرته أبدا أو مدة معينة) كسنة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع (فإن) حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية وإن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) لأنها لم تصادف محلا (وتصح ب) ما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث وماشية (وبزيت متنجس) لغير مسجد (و) للموصى (له ثلثهما) أي ثلث الكلب والزيت المتنجس (ولو كثر المال إن لم تجز الورثة) لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية (وتصح بمجهول كعبد وشاة) لأنها إذا صحت

بالمعدوم فالمجهول أولى (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم (العرفي) في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز و التبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل (وإذا أوصى بثلثه) أو نحوه (فاستحدث مالا ولو دية) بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته (دخل) ذلك (في الوصية) لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه (ومن أوصي له بمعين فتلف) قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول (بطلت) الوصية لزوال حق الموصى له (وإن تلف المال غيره) أي غير المعين الموصى به (فهو للموصى له) لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) وإلا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية وإن كان ماعدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

+ الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء (وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة) فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية وكذا لو أسقط لفظ مثل (فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه) أو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصى له (الثلث) لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه (وإن كانوا ثلاثة ف) للموصى (له الربع) لما سبق (وإن كان معهم بنت فله التسعان) لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالاثنان منها تسعان (وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين) ذلك الوارث (كان له مثل ما لأقلهم نصيبا) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه (فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت (ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة وإن أوصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله وهكذا (و) إن أوصى (بسهم من ماله فله سدس) بمنزلة سدس مفروض وهو قول علي وابن مسعود لأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس (و) إن أوصى (بشيء أو جزء أو حظ) أو نصيب أو قسط (أعطاه الوارث ما شاء) مما يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه

ج ٣ - ص ١٥

باب الموصى إليه

+ لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم (تصح وصية المسلم إلى كل) مسلم (مكلف عدل رشيد ولو) امرأة أو مستورا عاجزا ويضم إليه أمين أو (عبدا) لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر (ويقبل) عبد غير الموصي (بإذن سيده)

لأن منافعه مستحقه له فلا يفوتها عليه بغير إذنه (وإذا أوصى إلى زيد و) أوصى (بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا) كما لو أوصى إليهما معا (ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله) موص (له) لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه (ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم) ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه (يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره) لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة (ومن وصي) إليه (في شيء لم يصر وصيا في غيره) لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا

أخرجه مما في يده باطنا وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه (وإن ظهر على الميت دين يستغرق) تركته (بعد تفرقه الوصي) الثلث الموصى إليه بتفرقته (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئا لأنه

معذور بعدم علمه بالدين وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم (وإن قال ضع ثلثي حيث شئت) أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت (لم يحل) للوصي أخذه (له) لأنه تمليك ملكه بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا (ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي

تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها فإن لم يكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك

11 كتاب الفرائض

+ جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم

ولفظه له (وهي) أي الفرائض (العلم بقسمة المواريث) جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت ويقال له أيضا التراث ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفرضيا وفرائضيا وقد منعه بعضهم ورده غيرهم (أسباب الإرث) وهو انتقال مال الميت إلى حي بعد ثلاثة أحدها (رحم) أي قرابة قربت أو بعدت قال تعالى ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ و الثاني (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح قال تعالى ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ﴾ الآية (و) الثالث (ولاء) عتق لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لامن الأم والعم لغير أم وابنه والزوج وذو الولاء ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة (والورثة) ثلاثة (ذو فرض وعصبة و) ذو (رحم) ويأتي بيانهم وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وجميع النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة وممكن الجمع بين الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين (فذوو الفروض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات) الواحدة فأكثر (وبنات الابن) كذلك (والأخوات من كل جهة) كذلك (والإخوة من الأم) كذلك ذكورا كانوا أو إناثا (فللزوج النصف) مع عدم الولد وولد الابن (ومع وجود ولد) وارث (أو ولد

ابن) وارث (وإن نزل) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا (الربع) لقوله تعالى ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ﴾ وللزوجة لقوله تعالى ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾ فإن كان فأكثر نصف حالتيه فيهما فلها الربع مع عدم

الفرع الوارث وثمن معه لكم ولد فلهن الثمن ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن لقوله تعالى ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى (و) عدم (ولد الابن) كذلك لقوله تعالى ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب (و) يرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر %

فصل

+ (والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع ولد أبوين أو) ولد (أب) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا (كأخ منهم) في مقاسمتهم المال أو ما أبقت

الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل سهم جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي (فإن نقصته) أي الجد (المقاسمة عن ثلث المال) إذا لم يكن معهم صاحب فرض (أعطيه) أي أعطي ثلث المال لجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين (ومع ذى فرض) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد (بعده) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر (الأحظ من المقاسمة) كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم (أو ثلث ما بقي) كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان (أو سدس الكل) كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة (فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (سوى السدس) كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة (أعطيه) أي أعطي الجد السدس الباقي (وسقط الإخوة) مطلقا لاستغراق الفروض التركة (إلا) الأخت (في الأكدرية) وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث

يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ثم برجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين

ج ٣ - ص ٢٤

للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة (ولا يعول) في مسائل الجد غيرها (ولا يفرض لأخت معه) أي مع الجد ابتداء (إلا بها) أي بالأكدرية وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه (وولد الأب) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر (إذا انفردوا) عن ولد الأبوين (معه) أي مع الجد (كولد الأبوين) فيما سبق (فإن اجتمعوا) أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب (ف) إذا (قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب) كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب (و) تأخذ (أنثاهم) إذا كانت واحدة (تمام فرضها)

وهو النصف (وما بقي لولد الأب) فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب ما بقي وهو سهم فإن كانت الشقيقات اثنتين فأكثر لم يتصور ان يبقى لولد الأب شيء %

فصل في أحوال الأم

+ (وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا لقوله تعالى ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ أو اثنين فأكثر (من إخوة أو أخوات) أو منهما لمفهوم قوله تعالى ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ و لها (الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات لقوله تعالى ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ و ثلث الباقي وهو في الحقيقة إما (السدس مع زوج وأبوين) فتصح من ستة (و) إما (الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما) أي مثلا النصيبين في المسألتين ويسميان بالغراوين

والعمريتين قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط %

فصل في ميراث الجدة

+ في ميراث الجدة (ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب) فقط (وإن علون أمومة السدس) لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم أخرجه أبو عبيد والدارقطني (فإن) انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث و (تحاذين) أي تساوين في القرب أو البعد من الميت (ف) السدس (بينهن) لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى (ومن قربت) من الجدات (ف) السدس (لها وحدها) مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (وترث أم الأب و) أم (الجد معهما) أي مع الأب والجد (ك) ما يرثان (مع العم) روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم (وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلثي السدس) وللأخرى ثلثه (فلو تزوج بنت خالته) فأتت بولد (فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته) فأتت بولد (فجدته أم

أم أم وأم أبي أبيه) فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث %

4 فصل

في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات + (والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها) بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾ ثم هو أي النصف (لبنت ابن وحدها) عند عدمها (لأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها (أو) أخت (لأب وحدها) عند عدم الشقيقة وانفرادها (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب (فأكثر) لقوله تعالى ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ﴾ ما إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عما يساويها ويعصبها أو يحجبها (ثم) ترك

وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين وقال تعالى في الأختين ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴾ إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (والسدس لبنت ابن فأكثر) وإن نزل أبوها تكملة الثلثين (مع بنت) واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري (ولأخت فأكثر لأب مع أخت) واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب (مع عدم معصب فيهما) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (فإن استكمل البنات الثلثين) بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن (أو) استكمل الثلثين (هما) أي بنت وبنت ابن (سقط من دونهن) كبنات ابن ابن (إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن) أي بدرجتهن (أو أنزل منهن) من بنى الابن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه (وكذا الأخوات من الأب) يسقطن (مع أخوات الأبوين) اثنتين فأكثر (إن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه (والأخت فأكثر) شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر (ترث ما فضل بالتعصيب عن فرض البنت) أو بنت الابن (فأزيد) أي فأكثر فالأخوات النصف وللشقيقة الباقي ويسقط

الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت (وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على انثاهم لقوله تعالى ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ﴾ مع البنات أو بنات الابن عصبات ففي

بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي ، ويسقط الأخ لأب بالشقية لكونها صارت عصبة مع البنت (وللذكر) الواحد أو الأنثى الواحدة ، أو الخنثى (من ولد الأم السدس ، ولاثنين) منهم ذكرين أو أثنتين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالتسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ، لقوله تعالى " 4 : 12 " وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم %

فصل في الحجب

+ وهو لغة المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان وهو المراد هنا (يسقط الأجداد بالأب) لإدلائهم به (و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك (و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة (و) يسقط (ولد الابن) بالابن ولم لم يدل به لقربه (و) يسقط (ولد الأبوين) ذكرا كان أو أنثى (بابن وابن ابن) وإن نزل (وأب) حكاه ابن المنذر اجماعا (و) يسقط (ولد الأب بهم) أي بالابن وابنه وإن نزل والأب (وبالأخ لأبوين) وبالأخت لأبوين إذا

صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن (و) يسقط (ولد الأم بالولد) ذكرا كان أو أنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأبيه) وإن علا (ويسقط به) أي بأبي الأب وإن علا (كل ابن أخ و) كل (عم) وابنه لقربه ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا

باب العصبات

+ من العصب وهو الشد سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض (وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة) كالأب والابن وابن الابن والعم ونحوهم واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين (ومع ذي فرض يأخذ ما بقي) بعد ذوي الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة (فأقربهم ابن فابنة وإن نزل) لأنه جزء الميت (ثم الأب) لأن سائر العصبات يدلون به (ثم الجد) أبوه (وإن علا) لأنه أب وله إيلاء (مع عدم أخ لأبوين أو لأب) فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم (ثم هما) أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب (ثم بنوهما) أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا (أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك) فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب (ثم أعمام أبيه لأبوين ثم) أعمام أبيه (لأب ثم بنوهم كذلك) يقدم ابن الشقيق على ابن الأب (ثم أعمام جدهم ثم بنوهم كذلك) ثم أعمام أبي جدة ثم بنوهم كذلك وهكذا (لا يرث بنو أب أعلى) وإن قربوا (مع بني أب أقرب وإن نزلوا) لحديث ابن عباس يرفعه ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة (فأخ لأب) وابنه وإن نزل (أولى من عم) ولو شقيقا (و) من (ابنه و) أخ لأب أولى من (ابن

أخ لأبوين) لأنه أقرب منه (وهو) أي ابن الأخ لأبوين (أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين) لقربه (ومع الاستواء) في الدرجة كأخوين وعمين (يقدم من لأبوين) على من لأب لقوة القرابة (فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق) ولو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه (ثم عصبته) الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذووا الأرحام %

فصل

+ (يرث الابن) مع البنت مثليها (و) يرث (ابنه) أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها لقوله تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ و يرث (الأخ لأبوين) مع أخت لأبوين مثليها (و) يرث الأخ (لأب مع أخت مثليها) لقوله تعالى ﴿ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ أو العم وابن العم وابن المعتق وأخيه (لا ترث أخته معه شيئا) لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم (وأبناء عم أحدهما أخ لأم) للميتة (أو زوج) لها (له فرضه) أولا (والباقي) بعد فرضه (لهما) تعصيبا فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا (ويبدأ ب) ذوي (الفروض) فيعطون فروضهم (وما بقي للعصبة) لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة (ويسقطون) أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء (في الحمارية) وهو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد

الأبوين فقال بعضهم ياأمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم ولذلك سميت بالحمارية

ج ٣ - ص ٣١

باب أصول المسائل والعول والرد

+ أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها (والفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس) هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد (والأصول سبعة) أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول (فنصفان) من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين (أو نصف وما بقي) كزوج وعم (من اثنتين) مخرج النصف (وثلثان) وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم (أو ثلث وما بقي) كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث (أو هما) أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرهما (من ثلاثة) لتساوي مخرج الفرضين فيكتفي بأحدهما (وربع) وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع (أو ثمن وما بقي) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن (أو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع (و) ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن (فهذه أربعة) أصول (لا تعول) لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة (والنصف مع الثلثين) كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة (أو) النصف مع (الثلث) كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين أو النصف مع (السدس) كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس (أو هو) أي السدس (وما بقي) كأم وابن (من ستة) مخرج السدس

(وتعول) الستة) (إلى عشرة شفعا ووترا) فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة وثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها و إلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها (والربع مع الثلثين) كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين (أو) الربع مع

(الثلث) كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك (أو) الربع مع (السدس) كزوج وأم وابن (من اثني عشر) للتوافق (وتعول) الإثنا عشر (إلى سبعة عشر وترا) فتعول لثلاثة كزوج وبنتين وأم وخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ (والثمن مع السدس) كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين (أو) الثمن مع (ثلثين) كزوجة وبنتين وأخ شقيق (من أربعة وعشرين) للتباين (وتعول) مرة واحدة (إلى سبعة وعشرين) ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين وتسمى المنبرية (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة) معهم (رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي بقدر فرضه لقوله تعالى ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وابنتان من خمسة وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم أصل مسألة الزوج من اثنين له

واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لاينقسم فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم التصحيح

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

+ التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر (إذا انكسر سهم فريق) أي صنف من الورثة (عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم) كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهن في أصل أخت المسألة فتصح من تسعة لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة (أو) تضرب (وفقه) أي وفق عددهم (إن وافقه) أي عدد سهامهم (بجزء كثلث ونحوه) كربع ونصف وثمن (في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه) المسألة كزوج وست أخوات لغير أم أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من إحدى وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان (ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين كالمثال الأول (أو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة %

1 فصل

+ والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أوالنقل وفي الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته (إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه) أي ورثه ورثة الثاني (كالأول) أي كما يرثون الأول (كإخوة) أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا (فأقسمها) أي التركة (على من بقي) من الورثة ولا تلتفت للأول (وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح) المسألة (الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته) وهي عدد بنيه (وصحح المنكسر كما سبق) كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينها ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثنا عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح للأول اثنا عشر لا بنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة (وإن لم يرثوا الثاني كالأول) بأن اختلف ميراثهم (صححت) المسألة (الأولى) للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعلمت مسألة الثاني (وقسمت أسهم الثاني) من الأول (على) مسألة (ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها) كرجل خلف

زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثلاثة من أخيه وسهم منها (وإن لم تنقسم) سهام الثاني على

مسألته (ضربت كل الثانية) إن باينتها سهام الثاني (أو) ضربت (وفقها للسهام) إن وافقتها (في الأولى) فما بلغ فهو الجامعة (ومن له شيء منها) أي من الأولى (فاضربه فيما ضربته فيها) وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق (ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت) الثاني أي في عدد سهامه من الأول عند المباينة (أو وفقه) عند الموافقة ومن يرث منهما يجمع ماله منها فما اجتمع (فهو له) مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها إحدى وعشرون وللأخ في الأولى ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين (وتعمل في) الميت (الثالث فأكثر عملك

في) الميت (الثاني مع الأول) فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فأكثر %

2 فصل في قسمة التركات + والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم (إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء) كنصف وعشر (فله) أي فلذلك الوارث من التركة (كنسبته) فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين فالمسألة من خمسة عشر للزوج منها ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس المسألة وثلث خمسها فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر

4 باب ذوي الأرحام

+ وهم كل قريب ليس بذى قرب ولا عصبة و (يرثون بالتنزيل) أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة (الذكر والأنثى) منهم (سواء) لأنهم لا يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات) مطلقا (كأمهاتهن وبنات الإخوة) مطلقا كآبائهن (و) بنات (الأعمام لأبوين أو لأب) كآبائهن (وبنات بنيهم) أي بنات الأخوات أو بني الأعمام كآبائهن (

وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبوا الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبى أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث) بفرض أو تعصيب (لمن أدلى به) من ذوي الأرحام ولو بعد

فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم (فإن أدلى جماعة بوارث) بفرض أو تعصيب (واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم) كإرثهم منه لكن الذكر كالأنثى (فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى) لهذه المنفردة (حق) أي إرث (أمها وللأولين حق أمهما) سوية بينهما (وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه) أي مع من أدلوا به (كميت اقتسموا إرثه) على حسب منازلهم منه (فإن خلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم (وثلاث عمات متفرقات) كذلك (فالثلث) الذي كان للأم (للخالات أخماسا) لأنهن يرثن الأم كذلك (والثلثان) اللذان كانا للأب (للعمات أخماسا) لأنهن يرثنه كذلك (وتصح من خمسة عشر) للاجتزاء بأحد الخمسين لتماثلهما واضربهما في أصل المسألة ثلاثة للخالات من ذلك خمسة للشقيقة ثلاثة وللتي لأب سهم وللتي لأم سهم وللعمات عشرة للتي من قبل الأبوين ستة وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان (وفي ثلاثة أخوال متفرقين) أي أحدهم شقيق للأم والآخر لأبيها والآخر لأمها (لذي الأم السدس) كما يرثه من أخته لو ماتت (والباقي لذي الأبوين) وحده لأنه يسقط الأخ لأب (فإن كان معهم) أي مع الأخوال (أبو أم أسقطهم) لأن الأب يسقط الإخوة (وفي ثلاث

بنات عمومة متفرقين) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم (المال للتي للأبوين) لقيامهن مقام آبائهن فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها (وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم) كأنهم أحياء (فما صار لكل واحد) من المدلى بهم (أخذه المدلى به) من ذوي الأرحام لأنه وارثه (وإن سقط بعضهم ببعض عملت به) فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأب وبنت الأخ تدلي بالأخ ويسقط بعيد من وارث بأقرب

ب منه إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا والجهات التي يرث بها ذووا الأرحام ثلاثة (أبوة) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد (وأمومة) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها (وبنوة) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن و من أدلى بقرابتين ورث بهما ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذي الرحم ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة نكالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم للخالة سهم ولبنتي الأختين لأبوين أربعة ولبنتي الأختين لأم سهمان

5 باب ميراث الحمل

+ بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى (و) ميراث (الخنثى المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته (من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (فطلبوا القسمة وقف للحمل) إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة (الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين) لأن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف للحمل إرث

ذكرين لأنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس وللأم السدس كذلك (فإذا ولد أخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده

(ومن لا يحجبه) الحمل (يأخذ إرثه كاملا (كالجدة) فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه (ومن ينقصه) الحمل (شيئا) يعطى (اليقين) كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي (ومن سقط به) أي بالحمل (لم يعط شيئا) للشك في إرثه (ويرث) المولود (ويورث إن استهل صارخا) لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود (أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد) منه (دليل) على (حياته) كحركة طويلة أو سعال لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة (غير حركة) قصيرة (واختلاج) لعدم دلالتها على الحياة المستقرة وإن ظهر بعضه فاستهل) أي صوت (ثم خرج ومات لم يرث) ولم يورث كما لو لم يستهل (وإن جهل المستهل من التوأمين) إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى (واختلف إرثهما) بالذكورة والأنوثة (يعين بقرعة) كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه ويرث

صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه (والخنثى) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو (المشكل) فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة (يرث نصف ميراث ذكر) إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى (ونصف ميراث أنثى) إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه

في الآخرى أو وفقها فابن وولد خنثى مشكل مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينين فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصح من اثنا عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه

باب ميراث المفقود

وهو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت (من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة) وسياحة (انتظر به تمام تسعين سنه منذ ولد) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم (وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مغازة مهلكة) كدرب الحجاز (انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف) أي فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين وغلبة الهلاك بعد الأربع سنين فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئا به (فإن

موت مورثه في مدة التربص) السابقة (أخذ كل وارث إذا) أي حين الموت (اليقين) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته (ووقف على مابقي) حتى يتبين أمر المفقود فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين (فإن قدم) المفقود (أخذ نصيبه) الذي وقف له (وإن لم يأت) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه (فحكمه) أي حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلفه مورثه فيقضي منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنهم

7 باب ميراث الغرقى

+ جمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم (إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار) معا فلا توارث بينهما (و) إن (جهل السابق بالموت) أو علم ثم نسي (ولم يختلفوا فيه) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر (ورث كل واحد) من الغرقى ونحوهم (من الآخر

من تلاد ماله) أي من قديمه وهي بكسر التاء (دون ما ورثه منه) أي من الآخر (دفعا للدور) هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال يصير مال كل واحد لمولى الآخر وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا ولم يتوارثا

8 باب ميراث أهل الملل

+ جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة من موانع الإرث اختلاف الدين ف (فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء) لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث

مورثه المسلم فيرث (ولا) يرث (الكافر المسلم إلا بالولاء) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق (و) اختلاف الدارين ليس بمانع ف (يتوارث الحربي والذمي والمستأمن) إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص (وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى (والمرتد لايرث أحدا) من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من الأديان (وإن مات) المرتد (على ردته فماله فيء) لأنه لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه (ويرث المجوس بقرابتين) غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما (إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم) فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا (وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح أو تسر ويثبت النسب (ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم) كأمه وبنته وبنت أخيه (ولا) إرث (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أسلم) كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من الرضاع

رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان + (من أبان زوجته في صحته) لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرضه غير المخوف ومات به) لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق (أو) أبانها في مرضه (المخوف ولم يمت به لم يتوارثا) لانقطاع النكاح وعدم التهمة (بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدته) سواء كان في المرض أو في الصحة لأن الرجعية زوجة (وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها) بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا (أو علق

إبانتها في صحته على مرضه أو) علق إبانتها (على فعل له) كدخوله الدار (ففعله في مرضه) المخوف (ونحوه) كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف (لم يرثها) إن ماتت لقطعه نكاحها (وترثه) هي (في العدة وبعدها) لقضاء عثمان رضي الله عنه (ما لم تتزوج أو ترتد) فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها مادامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه

10 باب الاقرار بمشارك في الميراث

+ (إذا أقر كل الورثة) المكلفين (ولو أنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإرث (بوارث للميت) من ابن أو نحوه (وصدق) المقر به (أو كان) المقر به (صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه) بشرط أن يمكن كون

المقر به من الميت وإن لاينازع المقر في نسب المقر به (و) ثبت (إرثه) حيث لا مانع لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها فكذلك في النسب ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا (وإن أقر) به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط وأخذ الفاضل بيده أو مافي يده إن أسقطه فلو أقر (أحد ابنيه بأخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به (وإن أقر ببنت فلها خمسة) أي خمس ما بيده لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يبقى خمسة فيدفعه لها وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسأله الإنكار وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها ولمقربه ما فضل

11 باب ميراث القاتل والمبعض والولاء $ + الولاء بفتح الواو والمد أي ولاء العتاق (من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا) كحفر بئر تعديا أو نصب سكين (بلا حق لم يرثه إن لزمه) أي القاتل (قود أو دية أو كفارة) على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك في موطئه وأحمد (والمكلف وغيره) أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا (سواء) لعموم ما سبق (وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا) أي غير ردة (أو ببغي) أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي (أو) ب (صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (أو قتل العادل الباغي وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث (ولا يرث الرقيق) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي (ولا يورث) لأنه لا مال له (ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية) لقول علي وابن مسعود وكسبه وإرثه بحريته لورثته فابن نصفه حر وأم وعم حران للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم (ومن أعتق عبدا) أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد أو أعتقه في زكاة أو كفارة (فله عليه الولاء) لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله

ويرث ذو الولاء مولاه (وإن اختلف دينهما) لما تقدم فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن) أو باشرن عتقه أو عتق عليهن بنحو كتابة (أو أعتقه من أعتقن) أي عتيق عتيقهن أو أولادهن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصي به ولا يورث فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده ولو مات ابنا السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء وتسمى مسألة القضاة يروى عن مالك أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها

كتاب العتق

+ هو لغة الخلوص وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (وهو من أفضل القرب) لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل (ويستحب عتق من له كسب) لانتفاعه به

(وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له وكذا من يخاف منه زنا أو فسادا وإن علم ذلك منه أو ظن حرم وصريحه نحو أنت حر أو محرر أوعتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقك وكناياته نحو خليتك والحق بأهلك ولا سبيل ولا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه

بالملك ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد (ويصح تعليق العتق بموت

وهو التدبير) سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره

باب الكتابة

+ وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع لأنها تجمع نجوما وشرعا (بيع) سيد (عبده نفسه بمال) معلوم يصح السلم فيه (مؤجل في ذمته) بأجلين فأكثر (وتسن) الكتابة (مع أمانة العبد وكسبه) لقوله تعالى ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ وتكره الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة (ويجوز بيع المكاتب) لقصة بريرة ولأنه قن ما بقي عليه درهم (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (فإن أدى) المكاتب (له) أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة (عتق وولاءه له) أي للمشتري أو اشتراه (عاد قنا) فإذا حل نجم ولم يؤديه المكاتب فليسده الفسخ كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم انتظاره ثلاثا لنحو بيع عرض ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ﴿ وآتوهم ﴾ (وإن عجز) المكاتب

عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروي مرفوعا عن علي

باب أحكام أمهات الأولاد

+ أصل أم أمهة ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل (إذا أولد حر أمته) ولو مدبرة أو مكاتبة (أو) أولد (أمة له ولغيره) ولو كان له جزء يسير منها (أو أمة لولده) كلها أو بعضها ولم يكن الابن

وطئها قد (خلق ولده حرا) بأن حملت به في ملكه (حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان) ولو خفيا (لا) بالقاء (مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله) ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطىء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه (وأحكام أم الولد) ك (أحكام الأمة) القن (من وطء وخدمة وإجارة ونحوه) كإعارة وإيداع لأنها مملوكة له مادام حيا (لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له) أي لنقل الملك فالأول (كوقف وبيع) وهبة وجعلها صداقا ونحوه (و) الثاني ك (رهن و)

كذا (نحوها) أي نحو المذكورات كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني وتصح كتابتها فإن أدت في حياته عتقت وما بقي بيدها لها وإن مات وعليها شيء عتقت وما بيدها للورثة ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها وإذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت وللورثة القصاص في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها

13

ج ٣ - ص ٥٩

كتاب النكاح

هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة

لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير (وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة) لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له (ويجب) النكاح (على من يخاف زنا بتركه) ولو ظنا من رجل وامرأة لأنه طريق إعفافه نفسه وصونها عن الحرام ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير (ويسن نكاح واحدة) لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم قال الله تعالى ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ دينة ﴿ لحديث ﴾

أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه (أجنبية) لأن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم (بكر) لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه (ولود) أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس يرفعه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد (بلا أم) لأنها ربما أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره الخطبة (و) يباح (له) أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته (نظر ما يظهر غالبا) كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود (مرارا) أي يكرر النظر (بلا خلوة) إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمه وذات

محرم ولعد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة ويحرم خلوة ذكر

غير محرم بامرأة (ويحرم التصريح بخطبة المعتدة) كقوله أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ سواء كانت المعتدة (من الوفاة والمبانه) حال الحياة (دون التعريض) فيباح لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية (ويباحان لمن أبابها بدون الثلاثة) لأنه يباح

له نكاحها في عدتها (كرجعية) فإن له رجعتها في عدتها (ويحرمان) أي التصريح والتعريض (منها على غير زوجها) فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح (والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه) إذا كانت بائنا (ما يرغب عنك ونحوهما) كقوله لاتفوتيني بنفسك وقولها

إن قضي شيء كان (فإن أجاب ولي مجبرة) ولو تعريضا لمسلم (أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها) بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي (وإن رد) الخاطب الأول (أو أذن) أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت (أو جهلت الحال) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول (جاز) للثاني أن يخطب (ويسن العقد يوم الجمعة مساء) لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبله (بخطبة ابن مسعود) وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ

بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه %

1 فصل في أركان النكاح

+ (وأركانه) أي أركان النكاح ثلاثة أحدها (الزوجان الخاليان من الموانع) كالمعتدة (و) الثاني (الإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه (و) الثالث (القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه (ولا يصح) النكاح (ممن لايحسن) اللغة (العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت)

لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية (و) لا يصح قبول إلا بلفظ (قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت) أو رضيت ويصح النكاح من هازل وتلجئة (ومن جهلهما) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة (فإن تقدم القبول) على الإيجاب (لم يصح) لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى

وجد قبله لم يكن قبولا (وإن تأخر) أي تراخي القبول (عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد (وإن تفرقا قبله) أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا (بطل) الإيجاب للإعراض عنه وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام %

1 فصل في شروط النكاح

+ (وله شروط (أربعة (أحدها تعيين الزوجين) لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون (فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها) باسمها (أو وصفها بما تتميز به) كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز (أو قال زوجتك بنتي وله) بنت (واحدة لاأكثر صح) النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح %

2 فصل

+ الشرط (الثاني رضاهما) فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع (إلا البالغ المعتوه) فيزوجه أبوه أو وصية في النكاح (و) إلا (المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب) إذا تم لها تسع سنين (فإن الأب ووصيه

في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم) كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم أو (كالسيد مع إمائه) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن (و) كالسيد مع (عبده الصغير) فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير (ولا يزوج باقي الأولياء) كالجد والأخ والعم (صغيرة دون تسع) بحال بكرا كانت أو ثيبا (ولا) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح (صغيرا) إلا الحاكم لحاجة (ولا) يزوج غير الأب ووصيه فيه (كبيرة عاقلة) بكرا أو ثيبا (ولا بنت تسع) سنين كذلك (إلا بإذنها) لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره رواه أحمد وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه أحمد ومعناه في حكم المرأة (وهو) أي الإذن (صمات البكر) ولو ضحكت أو بكت (ونطق الثيب) بوطء في

القبل لحديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة %

3 فصل

+ الشرط (الثالث الولي) لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين (وشروطه) أي شروط الولي سبعة (التكليف) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره (والذكورية) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى (والحرية) لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى (والرشد في العقد) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه (واتفاق الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما (سوى ما يذكر) كأم ولد

لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة (والعدالة) ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك (فلا تزوج امرأة نفسها ولاغيرها) لما تقدم (ويقدم أبو المرأة) الحرة (في إنكاحها) لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة (ثم وصيه فيه) أي في النكاح لقيامه مقامه (ثم جدها لأب وإن علا) الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب (ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا) الأقرب فالأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت بعدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج رسول الله فزوجه رواه النسائي (ثم أخوها لأبوين ثم لأب) كالميراث (ثم بنوهما كذلك) وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب (ثم عمها لأبوين ثم لأب) لما تقدم (ثم بنوهما كذلك) على ما سبق في الميراث (ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث) فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة (ثم المولى المنعم) بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها (ثم أقرب عصبته نسبا) على ترتيب الميراث (ثم) إن عدموا فعصبته (ولاء) على ما تقدم (ثم السلطان) وهو الإمام

أو نائبه قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي أمة

سيدها ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام (فإن عضل) الولي (الأقرب) بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر (أو لم يكن) الأقرب (أهلا) لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا (أو غاب) الأقرب (غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) فوق مسافة القصر أو جهل مكانه (زوج) الحرة الولي (الأبعد) لأن الأقرب هنا كالمعدوم (وإن زوج الأبعد أو) زوج (أجنبي) ولو حاكما (من غير عذر) للأقرب (لم يصح) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو

كان الأقرب لا يعلم أنه عصبته أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل وولي مايشترط فيه ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانة ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع ويتعين من أذنت له منهم ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله تزوجتها %

4 فصل

+ الشرط (الرابع الشهادة) لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا (فلا يصح) النكاح (إلا بشاهدين عدلين) ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح (ذكرين مكلفين سميعين ناطقين) ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ولا يبطله

تواص بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط والإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده (وليست الكفاءة وهي) لغة المساواة وهنا (دين) أي أداء الفرائض واجتناب النواهي (ومنصب وهو النسب والحرية) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها (شرطا في صحته) أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح

أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه بل شرط للزوم (فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي) أو حرة بعبد (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء) حتى من حدث (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل

1 باب المحرمات في النكاح

+ وهن ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره بقوله (تحرم أبدا الأم وكل جدة) من قبل الأم أو الأب (وأن علت) لقوله تعالى ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ حلال وحرام وإن سفلت) وارثة كانت أو لا لعموم قوله تعالى ﴿ وبناتكم ﴾ (والبنت وبنت الابن وبنتاهما) أي

بنت البنت وبنت بنت الابن (من وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى ﴿ وأخواتكم ﴾ وبنتها أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها (وبنت ابنتها) وإن نزلت لقوله تعالى ﴿ وبنات الأخت ﴾ وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه) أي ابن الأخ (وبنتها) أي بنت بنت ابن أخيه (وإن سفلت) لقوله تعالى ﴿ وبنات الأخ ﴾ وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى ﴿ وعماتكم وخالاتكم ﴾ والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين (ويحرم بالرضاع) ولو محرما (ما يحرم بالنسب) من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما (أخت ابنه) من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب (ويحرم) بالمصاهرة ب (العقد) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة (زوجة أبيه) ولو من رضاع (وزوجة كل جد) وإن علا لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا ﴾ يحرم من النسب متفق عليه

(إلا أم أخته) وأم أخيه من رضاع) (و) إل ا ما نكح أباؤكم من النساء و تحرم أيضا بالعقد (زوجة ابنه وإن نزل) ولو من رضاع لقوله تعالى ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾ دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه (و) دون (أمهاتهن) فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ وتحرم أيضا (أم زوجته وجداتها) ولو من ضاع (بالعقد) لقوله تعالى ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ و تحرم أيضا الربائب وهن (بنتها) أي بنت الزوجة (وبنات أولادها) الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع (بالدخول) لقوله تعالى ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾

(فإن بانت الزوجة) قبل الدخول ولو بعد الخلوة (أو ماتت بعد الخلوة أبحن) أي الربائب لقوله تعالى ﴿ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما) أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته (وعمتاهما وخالتهما) وإن علتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم وحرمت على أبيه وابنه %

فصل في الضرب الثاني من المحرمات

+ (وتحرم لاتجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه عن أبي هريرة ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد (فإن طلقت) المرأة (وفرغت العدة أبحن) أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة (فإن تزوجهما) أي تزوج الأختين ونحوهما (في عقد) واحد لم يصح (أو) تزوجهما في (عقدين معا بطلا) لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا (فإن تأخر أحدهما) أي العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به (أو وقع) العقد الثاني (في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل) الثاني لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته ونحوها وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنين (وتحرم المعتدة) من الغير لقوله تعالى ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ و كذا صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجته

وتنقضي عدتها ومن ملك نحو أختين صح (المستبرأة من غيره) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب (و) تحرم (الزانية) على زان وغيره (حتى تتوب وتنقضي عدتها) لقوله تعالى ﴿ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ وتوبتها أن تراود فتمتنع (و) تحرم (مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره) بنكاح صحيح لقوله تعالى ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ و تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة (ولا ينكح كافر مسلمة) لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ ولا ينكح (مسلم ولو عبدا كافرة) لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ إلا حرة كتابية أبواها كتابيات لقوله تعالى ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾

ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها (ويعجز عن طول) أي مهر (حرة وثمن أمة) لقوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ الآية واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى (ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه (ولا) ينكح (سيد

أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (وللحر نكاح أمة أبيه) لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك (دون) نكاح (أمة ابنه) فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم (وليس للحرة نكاح عبد ولدها) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج الأخر أو ملكه بإرث أو غيره (أو) ملك (ولده الحر أو) ملك (مكاتبه) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده (الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما) ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق (ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا (حرم) وطؤها (بملك يمين) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى (إلا أمة كتابية) فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح (ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره) لعدم تحقق مبيح النكاح

باب الشروط والعيوب في النكاح

+ والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله (إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو) أن (لا يخرجها من دارها أو بلدها) أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع

ولدها الصغير (أو شرطت نقدا معينا) تأخذ منه مهرها (أو) شرطت (زيادة في مهرها صح) الشرط أوكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤها به (فإن خالفه فلها الفسخ) على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لايخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط

القسم الثاني فاسد وهو أنواع أحدها نكاح الشغار وقد ذكره بقوله

(وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا) أي زوج كل منهما الآخر وليته (ولا مهر) بينهما (بطل النكاحان) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للآخرى (فإن سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل غير قليل بلا حيلة (صح) النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط الثاني نكاح المحلل وإليه الإشارة بقوله (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه) أي التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع

بطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه (أو قال) ولي (زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح (أو) قال ولي زوجتك و (إذا جاء غد) أو وقت كذا (فطلقها أو وقته بمدة) بأ قال زوجتكها

شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج (بطل الكل) وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم % 1

فصل

+ (وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة) لها (أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر) منها (أو شرط فيه) أي في النكاح (خيارا أو) شرط (إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما) أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه (بطل الشرط) لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده (وصح النكاح) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه (وإن شرطها مسلمة) أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر (فبانت كتابية) فله الفسخ لفوات شرطه (أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو) شرط (نفي عيب لايفسخ به النكاح) بأن شرطها سميعة أو بصيرة (فبانت بخلافه فله الفسخ) لما تقدم وإن شرط صفه فبانت أعلى منها فلا فسخ ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينها وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته وإن كان المغرور عبدا فولده حر

أيضا يفديه إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار (وإن عتقت) أمة (تحت حر فلا خيار لها) لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم (بل) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها (تحت عبد) كله لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا مالم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها %

2 فصل في العيوب في النكاح

+ وأقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله (ومن وجدت زوجها مجبوبا) قطع ذكره كله (أو) بعضه (وبقي له مالا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو) ثبتت (ببينة على إقراره أجل سنة) هلالية (منذ تحاكمه) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة (فإن وطئها فيها) أي في السنة (وإلا فلها الفسخ) ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط (وإن اعترفت أنه وطئها) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة (فليس بعنين) لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت (ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا) لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته (و)

فصل

القسم الثاني يختص بالمرأة وهو (الرتق) بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة (والقرن) لحم زائد ينبت في الرحم فيسده (والعفل) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر (والفتق) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني (واستطلاق بول ونحوه) أى

غائط منها أو منه (وقروح سيالة في الفرج) واستحاضة (و) من القسم الثالث وهو المشترك (باسور وناصور) وهما داآن بالمقعدة (و) من القسم الأول (خصاء) أي قطع الخصيتين (وسل) لهما (ووجاء) لهما لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه (و) من المشترك (كون أحدهما خنثى واضحا) أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم (وجنون ولو ساعة وبرص وجذام) وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم (يثبت بكل واحد منهما الفسخ) لما فيه من النفرة (ولو حدث بعد العقد) والدخول كالإجارة (أو كان بالآخر عيب مثله)

أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه (ومن رضي بالعيب) بأن قال رضيت به (أو وجدت دلالته) من وطء أو تمكين منه (مع علمه) بالعيب (فلا خيار له) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس مارضي به (ولايتم) أي لايصح (فسخ أحدهما إلا بحاكم) فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه (فإن كان) الفسخ (قبل الدخول فلا مهر) لها

سواء كان الفسخ منه أو منها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها (و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول أو الخلوة ف (لها) المهر (المسمى) في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا

بسقط و (يرجع به على الغار إن وجد) لأنه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل وإن طلقت قبل دخول أو مات أحداهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار (والصغيرة والمجنونة والأمة لاتزوج واحدة منهن بمعيب) يرد به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح ويفسخ إذا علم وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم (فإن رضيت) العاقلة (الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع) لأن الحق في الوطء لها دون غيرها (بل) يمنعها وليها العاقد (من) تزوج (مجنون ومجذوم وأبرص) لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد (ومتى)

تزوجت معيبا لم تعلمه ثم (علمت العيب) بعد عقد لم تجبر على فسخ (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد ثم (حدث به) العيب بعده (لم يجبرها وليها على الفسخ) إذا رضيت به لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه

3 باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم

+ (حكمه كنكاح المسلمين) في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا (ويقرون على فساده) أي فاسد

النكاح (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم) بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم (ولم يرتفعوا إلينا) لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم (أو أسلم الزوجان) على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك (و) إذا تقرر ذلك فإن كانت (المرأة تباح إذا) أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود (أقرا) على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لامانع منه فلا مانع من استدامته (وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء نكاحها) حال الترافع أو الإسلام

كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره (فرق بينهما) لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته (وإن وطئ حربي حربية فأسلما) أو ترافعا إلينا (وقد اعتقداه نكاحا أقرا) عليه لأنا لانتعرض لكيفية النكاح بينهم (وإلا) يعتقداه نكاحا (فسخ) أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكار (ومتى كان المهر صحيحا أخذته) لأنه الواجب (وإن كان فاسدا) كخمر أو خنزير (وقبضته استقر) فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك (وإن لم تقبضه) ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة فيبطل وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل (و) إن (لم يسم) لها مهر (فرض لها مهر المثل) لخلو النكاح عن التسمية %

1 فصل

+ (وإن أسلم الزوجان معا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين (أو) أسلم (زوج كتابية) كتابيا كان أو غير كتابي (فعلى نكاحهما) لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية (فإن أسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لاتحل لكافر (أو) أسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين يسلم

(قبل الدخول بطل) النكاح لقوله تعالى ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ وقوله ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ فإن سبقته بالإسلام (فلا مهر) لها لمجيء الفرقة من قبلها (وإن سبقها) بالإسلام (فلها نصفه) أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه (وإن أسلم أحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة) لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيره نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما (فإن أسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما لما سبق (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بأن فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أسلم الأول) من الزوج أو

الزوجة فله نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم (وإن كفرا) أي ارتدا (أو) ارتد (أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة) كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد (و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح لاختلاف الدين ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة

باب الصداق

+ يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها

وهو عوض يسم في النكاح أو بعده (يسن تخفيفه) لحديث عائشه مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص بإسناده (و) سن (تسميته في العقد) لقطع النزاع وليست شرطا لقوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ ويسن أن يكون (من أربعمائة درهم) من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم (إلى خمسمائة) درهم وهو صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأس (و) لايقدر الصداق بل (كل ما صح) أن يكون (ثمنا أو أجرة صح) أن يكون (مهرا وإن قل) لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه (وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح) الإصداق لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى ﴿ أن تبتغوا بأموالكم ﴾ وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لاتكون لأحد بعدك مهرا (بل) يصح أن يصدقها

تعليم معين من (فقه وأدب) كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه ثم يتعلمه ويعلمها وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) لحديث لايحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه (وجب مهر المثل) بالعقد لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولايضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط %

1 فصل

+ (وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل) لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح (و) إن تزوجها (على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن) لي زوجة (بألف يصح) النكاح (بالمسمى) لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها (وإذا أجل الصداق أو بعضه) كنصفه أو ثلثه (صح) التأجيل (فإن عين أجلا) أنيط به (وإلا) يعينا أجلا بل أطلقا (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة (وإن أصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك (أو) أصدقها (خنزيرا ونحوه) نكمر صح النكاح كما لو بسم لها مهرا و (وجب) لها (مهر المثل) لما تقدم وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا (وأن وجدت) المهر (المباح معيبا) كعبد به نحو عرج (خيرت بين)

إمساكه مع (أرشه و) بين رده وأخذ (قيمته) إن كان متقوما وإلا فمثله وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجمع والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير (وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه الأب بالقبض مع النية (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقه لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد والأخ (فكل المسمى لها) أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل (ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح) ولو كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا

تمة المهر (وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته (و إن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب (ف) لها (مهر المثل) على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها (وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما لأن المرأة لم ترض بدونه وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق (في ذمة الزوج) إذا لم يعين في العقد (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) لأن الأب نائب عنه في التزويج والنائب لا يلزمه مالم يلتزمه كالوكيل فإن ضمنه غرمه ولأب قبض صداق محجور عليها لارشيدة ولو بكرا إلا بإذنها وإن تزوج عبد

بإذن سيدة صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده وبلا إذنه لا يصح فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته %

2 فصل

+ (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لايمنع وجوب جميعه بالعقد (ولها) أي للمرأة (نماء) المهر (المعين) من كسب وثمرة وولد ونحوها ولو حصل (قبل القبض) لأنه نما ملكها (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع (وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) فيفوت عليها (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) لأنه بمنزلة الغاصب إذا (ولهاالتصرف فيه) أي في المهر المعين لأنه ملكها إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصريفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك (وعليها زكاته) أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين (وإن طلق) من أقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (حكما) أي قهرا كالميراث لقوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾

دون قائمه أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لها (وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة (له نصف قيمته) أي قيمته العبد (بدون نمائه) المتصل لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته وإن باعته أو وهبته أو أقبضته أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى (وإن اختلف الزوجان) أو وليهما (أو ورثتهما) أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة أو نحوهما (فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته (و) إن اختلفا (في قبضه ف) القول قولها أو قول وليها أو ارثها مع اليمين حيث

لا بينة له لأن الأصل عدم القبض وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها %

ج ٣ - ص ١١٤

3 فصل

+ (يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر (أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ و يصح أيضا (تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما) أي أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي ف) يصح العقد و (لها مهر المثل بالعقد) لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه (ويفرضه) أي مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبها لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة وإن تراضيا ولو على قليل صح لأن الحق لايعدوهما ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقاه وإسقاطه (ومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل الإبانة) والخلوة (والفرض) فلها مهر المثل و (ورثه الآخر) لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح (ولها مهر) تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها (فإن طلقها) أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة (فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره) لقوله تعالى ﴿ ومتعوهن ﴾ على مثلها من (نسائها) أي

قراباتها كأم وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن ﴿ الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها (ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها (بالدخول) والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها (وإن طلقها)

أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي بعد الدخول (فلا متعة) لها بل لها المهر كما تقدم (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) ولا متعة سواء طلقها أو مات عنها لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه (و) إن افترقا (بعد أحدهما) أي الدخول أو الخلوة أو مايقرر الصداق مما تقدم (يجب المسمى) لها في العقد قياسا على الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها (ويجب مهر المثل لمن وطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة أو وطئت (بشبهة أو زنا كرها) لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه فأوجب القيمة وهي المهر (ولا يجب معه) أي مع المهر (أرش بكارة) لدخوله في مهر مثلها لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها والزانية المطاوعة لاشيء لها إن كانت حرة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه حاكم (وللمرأة)

قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) مفوضة كانت أو غيرها لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة زمنه (فإن كان) الصداق (مؤجلا) ولم يحل (أو حل قبل التسليم) لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب بالحال (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه (فإن أعسر) الزوج (بالمهر الحال فلها الفسخ) إن كانت حرة مكلفة (ولو بعد الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعشرته ويخير سيد الأمة لأن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة (ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في الترغيب

5 باب وليمة العرس

+ أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه

ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة (تسن) الوليمة بعقد ولو (بشاة فأقل) من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أو لم ولو بشاة وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس لكن قال في جمع يستحب أن لاتنقص عن شاة (وتجب في أول مرة) أي في اليوم الأول (إجابة مسلم يحرم هجره) بخلاف نحو رافضي متجاهر

بمعصية إن دعاه (إليها) أي إلى الوليمة (إن عينه) الداعي (ولم يكن ثم) أي في محل الوليمة (منكر) لحديث أبي هريرة يرفعه شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لايجب

فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم (فإن دعاه الجفلى) بفتح الفاء كقوله يأيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وغيره وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر (أو دعاه ذمي) أو من في ماله حرام (كرهت الإجابة) لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره (ومن صومه واجب) كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا و (دعا)

استحبابا (وانصرف) لحديث أبي هريرة يرفعه إذ دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم رواه أبو دواد (و) الصائم (المتنفل) إذا دعي أجاب و (يفطر إن جبر) قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت (ولا يجب) على من حضر (الأكل) ولو مفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال في شرح المقنع حديث صحيح ويستحب الأكل لما تقدم (وإباحته) أي إباحة الأكل (متوقفة على صريح إذن أو قرينة) ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام أذن فيه ولا يملكه من قدم إليه بل يملك على ملك صاحبه (وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها فإن كان (يقدر على تغييره حضر وغيره) لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر (وإلا) يقدر على تغييره (أبى) الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر رواه الترمذي (وإن حضر) من غير علم بالمنكر (ثم علم به أزاله) لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك (فإن دام) المنكر

(لعجزه) أي المدعو (عنه انصرف) لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه (وإن علم) المدعو (به) أي بالمنكر (ولم يره ولم يسمعه خير) بين الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ (وكره النثار والتقاطه) لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم وإن أخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف (ومن أخذه) أي أخذ شيئا من النثار (أو وقع في حجره) منه شيء (ف) هو (له) قصد تملكه أولا لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه (ويسن إعلان النكاح) لقوله عليه الصلاة

و السلام أعلنوا النكاح وفي لفظ أظهروا النكاح رواه ابن ماجه (و) بسن (الدف) أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج (فيه) أي في النكاح (للنساء) وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود قال في المستوعب و الترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور (تتمة) في جمل من آداب الأكل والشرب تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع وتخليل

ما علق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة وإذا شرب ناوله الأيمن ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه وكره رد شيء من فمه إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها وفعله مايستقذره من غيره ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقا وإن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره

باب عشرة النساء

+ العشرة بكسر العين الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر وهي هنا مايكون بين الزوجين من الألفة والانضمام (ويلزم) كلا من (الزوجين العشرة) أي معاشرة الآخر (بالمعروف) فلا يمطله بحقه ولايتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنة لقوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وقوله ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى ﴿ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ﴾

قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا (ويحرم مطل كل واحد) من الزوجين (بما يلزمه) للزوج (الآخر والتكره لبذله) أي بذل الواجب لما تقدم (وإذا تم العقد لزم تسليم) الزوجه (الحرة التي يوطأ مثلها) وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض (في بيت الزوج) متعلق بتسليم (إن طلبه) أي طلب الزوج تسليمها (ولم تشترط) في العقد (دارها أو بلدها) فإن اشترطت عمل بالشروط لما تقدم ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة (وإذا استمهل أحدهما) أي طلب المهلة ليصلح أمره (أمهل العادة وجوبا) طلبا لليسر والسهولة (لا لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك (ويجب تسليم الأمة) مع الإطلاق (ليلا فقط) لأنه زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا (ويباشرها) أي الزوج للاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة (ما لم يضر بها) (أو يشغلها عن فرض) باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب (وله) أي للزوج (السفر بالحرة) مع الأمن لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لها بالشروط وإلا فلها الفسخ كما تقدم والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إن الآخر ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه ولسيد سفر بعبده

المزوج واستخدامه نهارا (ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾ كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط

ضده) أي أن لا يسافر بها فيوفي الآية وكذا بعده قبل الغسل (و) في (الدبر) لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لايستحيي من الحق لاتأتوا النساء في أعجازهن رواه ابن ماجه ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة (وله إجبارها) أي للزوج إجبار زوجته (على غسل حيض) ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة (و) غسل (نجاسة) واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن (وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره) كظفر ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث وثوم لأنه يمنع كمال الاستمتاع وسواء كانت مسلمة أو ذمية ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو

نحوه (ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) في رواية والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب مايسكرها لا ما دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها %

1 فصل

+ (ويلزمه) أي الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع) ليال إلا إذا طلبت أكثر لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر وعند الأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف (و) له أن (ينفرد إذا أراد) الإنفراد (في الباقي) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته حرة له الإنفراد في ثلاث ليال من كل أربع ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين وهكذا (ويلزمه الوطء إن قدر) عليه (كل ثلث سنة مرة) بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي

فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها (وإن سافر فوق نصفها) أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم (فإن أبى أحدهما) أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته (فرق بينهما الحاكم) بطلبها وكذا إن ترك المبيت كالمؤلي ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه (وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد) لحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه (ويكره) الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه وتكره (كثرة الكلام) حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لاتكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة (و) يكره (النزع قبل فراغها) لقوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها (و) يكره (الوطء بمرأى أحد) أو مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه أحد غير طفل لايعقل ولو رضيعا (و) يكره (التحدث به) أي بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه أبو داود وغيره وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس سكبت

لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة (ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما) لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة (وله منعها) أي منع زوجته (من الخروج من منزله) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة (ويستحب إذنه) أي إذن الزوج لها في الخروج (أن تمرض محرمها) كأخيها وعمها أو لتعوده (وتشهد جنازته) لما 355 في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها (وله منعها من إجارة نفسها) لأنه يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت (و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته) أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذا لما فيه من إهلاك نفس معصومة وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع %

2 فصل في القسم

+ (و) يجب (عليه) أي على الزوج (أن يساوي بين زوجاته في القسم) لا في الوطء لقوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وتمييز إحداهما ميل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث (وعماده) أي القسم (الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس) فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها (ويقسم) وجوبا (لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة) بنحو جذام (ومجنونة مأمونة وغيرها) كمن آلى وظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن (وإن سافرت) زوجة (بلا إذنه أو بإذنه في

حاجتها أو أبت السفر معه أو) أبت (المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة) لأنها عاصية كالناشز وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها ويحرم أن تدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة فإن لبث أو جامع لزمه القضاء (ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه) أي إذن الزوج جاز (أو) وهبته (له فجعله ل) زوجة (أخرى جاز) لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا (فإن رجعت) الواهبة (قسم لها مستقبلا) لصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائة (ولا قسم) واجب على سيد (لإمائه وأمهات أولاده) لقوله تعالى ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ بل يطأ السيد (من شاء) منهن (متى شاء) وعليه أن لايعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن (وإن تزوج بكرا) ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ولو أمة (ثم دار) على نسائه (و) إن تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان (وإن أحبت) الثيب أن يقيم عندها (سبعا فعل وقضى مثلهن) أي مثل السبع (للبواقي) من ضراتها لحديث أم سلمة أن النبي صلى

الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما %

3 فصل في النشوز

+ وهو (معصيتها إياه فيما يجب عليها) مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (فإذا ظهر منها أماراته بأن لاتجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة) متثاقلة (أو متكرهة وعظها) أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة (فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها

(ما شاء) وهجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط لحديث أبي هريرة مرفوعا لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (فإن أصرت) بعد الهجر المذكور (ضربها) ضربا (غير مبرح) أي شديد لقوله صلى الله عليه وسلم لايجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولايزيد على عشرة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم لايجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة وله تأديبها على ترك الفرائض وإن ادعى كل ظلم صاحبة أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه

باب الخلع

+ وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس قال تعالى ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه (من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه) ومن لا فلا لأنه الزوجة (خلق زوجها أو خلقه) أبيح الخلع والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة (أو) كرهت (نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع) لقوله تعالى ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ﴾ بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة

فصار كالمتبرع (فإذا كرهت) ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ وتسن إجابتها إذا إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها (وإلا) يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة (كره ووقع) لحديث ثوبان مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة غير النسائي (فإن عضلها ظلما للافتداء) أي لتفتدي منه (ولم يكن) ذلك (لزناها تعالى ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة ﴾ أو نشوزها أو تركها فرضا

ففعلت) أي افتدت منه حرم ولم يصح لقوله مبينة فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق (أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيه) ولو بإذن الولي (أو) خالعت (الأمة بغير إذن سيدها لم يصح) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه (أو وقع الطلاق رجعيا إن) لم يكن تمام عدة أو (كان) الخلع المذكور (بلفظ الطلاق أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضا فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه ويصح الخلع ممن يصح طلاقة %

1 فصل

+ (والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته) أي كناية الطلاق (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها قال خلعت أو فسخت أو فاديت (ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق) روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ لسؤالها (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء) بأن ثم قال

﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ثم قال ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا (ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها) الزوج (به) روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي في الخلع ولا شرط فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب (لم يصح) الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض (ويقع الطلاق) المسئول على ذلك (رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) لخلوه عن العوض وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتهما فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما (وما صح مهرا) من عين مالية ومنفعة مباحة (صح الخلع به) لعموم قوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ خيار ويصح الخلع فيهما (وإن خالعها بغير عوض) لم يصح لأنه لايملك

و (يكره) خلعها (بأكثر مما أعطاها) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد ويصح الخلع إذا لقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل (ويصح) الخلع (بالمجهول كالوصية) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط يدخله المسامحة (فإن خالعته على حمل شجرتها أو) حمل (أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد) مطلق ونحوه (صح) الخلع وله ما يحصل في بيتها أو يدها (وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها (و) مع عدم (متاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على مافي بيتها من عبد (أقل مسماه) أي أقل مايطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل مايتناوله الاسم (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على مابيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم لأنها أقل الجمع %

2 فصل

+ (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها (متى) أعطيتني ألفا (أو إذا) أعطيتني ألفا (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت) بائنا (بعطيته) الألف (وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته أياة طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا وإن بان مستحقا لدم فقتل فأرش عيبه ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (وإن قالت اخلعني على ألف أو) اخلعني (بألف أو) اخلعني (ولك ألف ففعل) أي خلعها ولو لم يذكر الألف (بانت واستحقها) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب (و) إن قالت (طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها) لأنه أوقع ما استدعته وزيادة (وعكسه بعكسه) فلو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته (إلا في واحدة بقيت) من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقها) لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدارقطني (ولا) للأب (خلع ابنته بشيء من مالها)

لأنه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي

ويحرم خلع الحيلة ولا يصح (ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق) فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجتة وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق (وإن علق طلاقها بصفة) كدخول الدار (ثم أبانها) فوجدت الصفة حال بينونتها (ثم نكحها) أي عقد عليها بعد وجود الصفة (فوجدت) الصفة (بعده) أي بعد النكاح (طلقت) وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به (كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك (فلا) طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك لأنهما إذا ليسا محلا للوقوع

كتاب الطلاق

+ وهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت والاطلاق الإرسال وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (ويستحب للضرر) أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما وهي كالرجل فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى (ويجب) الطلاق (للإيلاء) على الزوج المؤلي إذا أبى الفيئة (ويحرم للبدعة) ويأتي بيانه (ويصح من زوج مكلف و) زوج (مميز يعقله) أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

وتقدم (ومن زال عقله معذورا) كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام

أو نشاف ونائم ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره (لم يقع طلاقه) لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ذكره البخاري في صحيحه (وعكسه الآثم) فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة (ومن أكره عليه) أي على الطلاق (ظلما) أي بغير حق بخلاف مول أبي الفيئة فأجبره الحاكم (بإيلام) أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما (له) أي للزوج (أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها) أي أحد المذكورات من إيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره (قادر) على ما هدده به بسلطة أو تغلب كلص ونحوه (يظن) الزوج (إيقاعه) أي إيقاع ما هدده (به فطلق تبعا) لقوله لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق لحديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والإغلاق الاكراه ومن قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر (ويقع الطلاق) بائنا لا الخلع (في نكاح مختلف فيه) كبلا ولي ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يكون بدعيا في حيض (و) يقع الطلاق (من الغضبان) ما لم يغم عليه كغيره (ووكيله) أي الزوج في الطلاق (كهو)

فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله (ويطلق) الوكيل (واحدة) فقط (و) يطلق في غير وقت بدعة (متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا) فلا يتعداهما ولا يملك تعليقا إلا بجعله له (وامرأته) إذا قال لها طلقي نفسك (كوكيله في طلاق نفسها) فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع

1 فصل وقوع الطلاق

+ (إذا طلقها مرة) أي طلقة واحدة (في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة) أي فهذا الطلاق موافق للسنة لقوله تعالى ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب للرجعة من طلاق في حيض فبدعة (فتحرم الثلاث إذا) أي يحرم

إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر فمن طلق زوجة ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده (وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما (فبدعة) أي فذلك طلاق بدعة محرم و (يقع) لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة إلا الترمذي (وتسن رجعتها) إذا طلق زمن البدعة لحديث ابن عمر (ولا سنة ولا بدعة) في زمن أو عدد (لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان) أي ظهر (حملها) فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك وإن قاله لمن لهاسنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذا (وصريحه) أي صريح الطلاق وهو ما وضع له (لفظ

الطلاق وما تصرف منه) كطلقتك وطالق ومطلقة اسم مفعول (غير أمر) كطلقي (و) غير (مضارع) كتطليقتين (و) غير (مطلقة اسم فاعل) فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق (فيقع) الطلاق (به) أي بالصريح (وإن لم ينوه جاد أو هازل) لحديث أبي هريرة يرفعه ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة إلا النسائي (فإن نوى بطالق) طالقا (من وثاق) بفتح الواو أي قيد (أو) نوى طالقا (في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد) أن يقول (طاهر فغلط) أي

سبق لسانه (لم يقبل) منه ذلك (حكما) لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر

ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته (ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع) الطلاق ولو أراد الكذب أو لك ينوه لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح صريح (أو) سئل الزوج (ألك امرأة فقال لا أراد الكذب) أو لم ينو به الطلاق (فلا) تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت (وكان صريحا) ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع

فصل كنايات الطلاق

+ (وكناياته) نوعان ظاهرة وخفية (فالظاهرة) في الألفاظ الموضوعة للبينونة (نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة) أي مقطوعة الوصلة (وأنت حرة وأنت الحرج) وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي (و) الكناية (الخفية) موضوعة للطلقة الواحدة (نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي) ولو غير مدخول بها (واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه) كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم ولفظ فراق وسراح

وما تصرف منهما غير ما تقدم (و لا يقع بكناية) ولو كانت (ظاهرة طلاق إلا ببينة مقرنة للفظ) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع (إلا حال خصومة أو) حال (غضب أو) حال (جواب سؤالها) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة (فلو لم يرده) في هذه الأحوال (أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما

بينه وبين الله تعالى (ويقع مع النية ب) الكناية (الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم (و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا

3 فصل الظهار والتحريم

+ (وإن قال) لزوجته (أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق) لأنه صريح في تحريمها (وكذلك ما أحل الله علي حرام) أو الحل علي حرام وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو (وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت

ثلاثا) لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه (وإن قال أعني به طلاقا فواحدة) لعدم ما يدل على الاستغراق (وإن قال) زوجته (كالميتة والدم والخنزير وقع مانواه من طلاق وظهار ويمين) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث (وإن لم ينو شيئا) من هذه الثلاثة (فظهار) لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم (وإن قال حلفت بالطلاق وكذب) لكونه لم يكن حلف به (لزمه) الطلاق (حكما) مؤاخذة له بإقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى (وإن قال) لزوجته (أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة) لأنه كناية ظاهرة وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس (ويتراخى) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت مالم يحد لها حدا أو (ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ) ما جعله لها أو ترد هي لأن ذلك يبطل الوكالة (ويختص) قوله لها (اختاري نفسك بواحدة بالمجلس المتصل مالم يزدها فيهما) بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت فيكون على ما قال لأن الحق له وقد وكلها فيه ووكيل كل إنسان يقوم مقامه واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو

الأزواج فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء (فإن ردت) الزوجة (أو وطئ) ها (أو طلق) ها (أو فسخ) خيارها قبله (بطل خيارها) كسائر الوكالات ومن طلق في قلبه لم يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ومميز ومميزة يعقلانه كالبالغين فيما تقدم

1 باب ما يختلف به عدد الطلاق

+ وهو معتبر بالرجال روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ف (يملك من كله حر أو بعضه) حر (ثلاثا و) يملك (العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به (فإذا قال) حر (أنت الطلاق أو أنت طالق أو) قال (علي) الطلاق (أو) قال (يلزمني) الطلاق (وقع ثلاثا بنيتها) لأن لفظه يحتمل ذلك (وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة مالم تكن نية أو سبب يخصصه بأحداهن وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة) لأنها لا يحتملها لفظه كقوله يا مائة طالق

وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة إن لم ينو أكثر (وإن طلق) من زوجته (عضوا) كيد أو أصبع (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) كنصف وسدس (أو) جزءا (معينا) كنصفها الفوقاني (أو) جزءا (مبهما) بأن قال لها جزؤك طالق (أو قال) لزوجته أنت طالق (نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض (وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه) فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق وعتق في ذلك كطلاق (وإذا قال ل) زوجة (مدخول بها أنت طالق وكرره) مرتين أو ثلاثا (وقع العدد) أي وقع الطلاق بعد التكرار فإن كرره مرتين وقع اثنتين وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا لأنه أتى بصريح الطلاق (إلا أن ينوي) بتكراره (تأكيدا يصح) بأن يكون متصلا (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة لا نصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه (وإن كرره ب بل) بأن قال أنت طالق بل طالق (أو ب ثم) بأن قال أنت طالق ثم طالق (أو بالفاء) بأن قال أنت طالق فطالق (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة وقع اثنتان) في مدخول بها لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق

الطلاق (وإن لم يدخل بها بانت بالأو ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة فثنتان ولو غير مدخول بها (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى %

1 فصل في الاستثناء في الطلاق

+ (ويصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق و) عدد (المطلقات) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف (فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة) لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول قال تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ﴾ يريد به البراءة من غير الله عز وجل (وإن قال) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة فطلقتان) لما سبق

وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث (وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة (صح الاستثناء) فلا تطلق لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام (دون عدد المطلقات) فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية وكذا لو قال نسائي الأ ربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع (وإن قال) لزوجاته (أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) لأن غير المتصل

يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لايمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه بطل) الاستثناء لما تقدم (وشرطه) أي شرط صحة الاستثناء (النية) أي نية الاستثناء (قبل كمال ما استثنى منه) فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث وكذا شرط متأخر ونحوه لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية

2 باب الطلاق في الماضي والمستقبل

+ (إذا قال) لزوجته (أنت طالق أمس أو) قال لها أنت طالق (قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع) الطلاق لأنه رفع

للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضى وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه (وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق) منه أو بطلاق سبق (من زيد وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد وقبل ذلك (قبل) منه ذلك لأن لفظه يحتمله فلا يقع عليه بذلك طلاق مالم تكن قرينة كغضب وسؤال طلاق (فإن مات) من قال أنت طالق أمس أو قبل أن انكحك (أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ (وإن قال) لزوجته (أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى قدومه لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض الأصحاب (ف) إن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر أو معه (لم تطلق) كقوله أنت طالق أمس (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي تبينا وقوعه لوجود الصفة فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر (فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا

(وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) لأنها كانت زوجة حينه (وبطل الطلاق المعلق) لأنه وقت وقوعه بائن فلا يلحقها (وعكسهما) أي يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور (بعد شهر وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمة (وإن قال) لزوجته هي (طالق قبل موتي) أو موتك أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ماقبل موته من حين عقد الصفة وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت لأن التصغير دل على التقريب (وعكسه) إذا قال أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق وإن قال يوم موتي طلقت أوله %

1 فصل

+ (و) إن قال (أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل) لذاته أو عادة كأن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو البهيمة (لم تطلق) لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد (وتطلق في عكسه فورا) لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم (وهو) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق (على النفي في

المستحيل مثل) أنت طالق (لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما) ك لأشربن ماء الكوز ولا ماء به أو لأطلعن الشمس أو لأطيرن فيقع الطلاق في الحال لما تقدم وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام (لغو) لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه لأن الغد لايأتي في اليوم بل يأتي بعد ذهابه وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث وإن لم يقل ثلاثا فواحدة (وإذا قال) لزوجته (أنت طالق في هذا الشهر أو) هذا (اليوم طلقت في الحال) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه (وإن قال) أنت طالق (في غد أو) يوم (السبت أو) في (رمضان طلقت في أوله) وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم (وإن قال أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت (دين وقبل) منه حكما لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما (و) إن قال (أنت طالق إلى شهر) مثلا (طلقت عند انقضائه)

روي عن ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه ويرجع ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال فيقع) في الحال (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة تطلق ب) انقضاء (اثني عشر شهرا) لقوله تعالى ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ﴾ أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد (فإن عرفها) أي السنة (باللام) كقوله أنت طالق إذا مضت السنة (طلقت بانسلاخ ذي الحجة) لأن أل للعهد الحضوري وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبإنسلاخه وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله وفي آخر تطلق في آخر جزء منه

3 باب تعليق الطلاق بالشروط

+ أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل ب إن أو إحدى أخواتها و (لا يصح) التعليق (إلا من زوج) يعلق الطلاق فلو قال إن تزوجت امرأة وفلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لانذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه

(فإذا علقه) أي علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر كإن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط (ولو قال عجلته) أي عجلت ما علقته لم يتعجل لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا (وإن قال) من علق الطلاق بشرط (سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع) الطلاق (في الحال) لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة (وإن قال) لزوجته (أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل) منه (حكما) لعدم ما يدل عليه وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها (وأدوات الشرط) المستعملة غالبا (إن) بكسر الهمزة وسكون النون

وهي أم الأدوات (وإذا ومتى وأي) بفتح الهمزة وتشديد الياء (ومن) بفتح الميم وسكون النون (وكلما وهي) أي كلما (وحدها للتكرار) لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار (وكلها) أي كل أدوات الشرط المذكورة (ومهما) وحيثما (بلا لم) أي بدون لم (أو نيته فور أو قرينته) أي قرينة الفور (للتراخي و) هي (مع لم للفور) إلا مع نية التراخي أو قرينته (إلا إن) فإنها للتراخي حتى مع لم (مع عدم نية فور أو قرينة) (فإذا قال) لزوجته (إن قمت) فأنت طالق (أو إذا) قمت فأنت طالق (أو متى) قمت فأنت طالق (أو أي وقت) قمت فأنت طالق (أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه وإن بعد القيام عن زمان الحلف (وإن تكرر الشرط

المعلق عليه) لم يتكرر (الحنث) لما تقدم (إلا في كلما) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق (و) إن قال إن (لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها (و) إن قال (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو إذا لم) أطلقك فأنت طالق (أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت) لما تقدم وإن قال (كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي واحدة بعد واحدة (فيه) أي في الزمن الذي مضى (طلقت المدخول بها ثلاثا) لأن كلما للتكرار (وتبين غيرها) أي غير المدخول بها (ب) الطلقة (الأولى) فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة (و إن) قال (إن قمت فقعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال إن قمت (ثم قعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال إن (قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال (إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم

لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها (و) إن عطف (بالواو) كقوله أنت طالق إن قمت وقعت (تطلق بوجودهما) أي القيام والقعود (ولو غير مرتبين) أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر لأن الواو لاتقتضي ترتيبا (و) إن عطف (بأو) بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت (بوجود أحدهما) أي بالقيام أو القعود لأن أو لأحد الشيئين وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأيت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا %

1 فصل في تعليقه بالحيض

+ (إذا قال) لزوجته (إن حضت فأنت طالق بأول حيض متيقن) لوجود الصفة فإن لم يتيقن أن حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليله لم تطلق (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها (وفيما إذا) قال إذا (حضت

نصف حيضة) فأنت طالق (تطلق) ظاهرا (في نصف عادتها) لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع لأن أيام

الحيض قد تطول وقد تقصر فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته بخلاف نحو قيام وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة %

2 فصل في تعليقه بالحمل

+ (إذا علقه بالحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا أو لدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه (طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة (وإن قال) لزوجته (إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وإنما يحرم وطؤها (في) الطلاق (البائن) دون الرجعي (وهي) أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق (عكس) المسألة (الأولى) وهي إن كان حاملا فأنت طالق (في الأحكام) فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ لأن

الأصل عدم الحمل وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطؤها إن كان وطىء في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر (وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين) إن كانت حاملا (بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا) بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين (وإن كان مكانه) أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين (إن كان حملك أو ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما (لم تطلق بهما) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا %

3 فصل في تعليقه بالولادة

+ يقع ما علق على ولادة بإلقاء ماتبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها (إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين) على الولادة (بأنثى) بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين (فولدت ذكرا ثم) ولدت (أنثى حيا) كان المولود (أو ميتا طلقت بالأول) ما علق به فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان (وبانت بالثاني ولم تطلق به) لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك وإن ولدتهما معها طلقت

ثلاثا (وإن أشكل كيفية وضعهما) بأن لم يعلم أوضعهما معا أو متفرقين (فواحدة) أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه %

4 فصل في تعليقه بالطلاق

+ (إذا علقه على الطلاق) بأن قال إن طلقتك فأنت طالق (ثم علقه على القيام) بأن قال إن قمت فأنت طالق (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط (وإن علقه) أي الطلاق (على قيامها) بأن قال إن قمت فأنت طالق (ثم) علق الطلاق (على طلاقه لها فقامت فواحدة) بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها (وإن قال) لزوجته (كلما طلقتك) فأنت طالق (أو) قال (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا) أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في

الثانية (طلقت في الأولى) وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق (طلقتين) طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه (و) طلقت في (الثانية) وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق (ثلاثا) إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله وتسمى السريجية %

5 فصل في تعليقه بالحلف

+ (إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال) لها (أنت طالق إن قمت) أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوة مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه (طلقت في الحال) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد (لا إن علقه) أي الطلاق (بطلوع الشمس ونحوه) كقدوم زيد

أو بمشيئتها (لأنه) أي التعليق المذكور (شرط لا حلف) لعدم اشتمال على المعنى المقصود بالحلف (و) من قال لزوجته (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو) قال لها (إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت) طلقة (واحدة) لأن إعادته حلف وكلام (و) إن أعاده (مرتين ف) طلقتان (ثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك وغير المدخول بها تبين بالأولى

ولا تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام %

6 فصل في تعليقه بالكلام

+ (إذا قال) لزوجته (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال) زجرا لها (تنحي أو اسكتي طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولا وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث لأنه كلمها ما لم ينو كلاما غير هذا فعلى ماينوي (و) من قال لزوجته (إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي بكلام (فعبدي حر انحلت يمينه) لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء (ما لم ينو عدم البداءه في مجلس آخر) فإن نوى ذلك فعل مانوى ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث ولو لم يسمع زيدا كلامها لغفلة أو شغل ونحوه أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم

بسمع لولا المانع وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينو مشافهتها وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه % 7 فصل في تعليقه بالإذن + (إذا قال) لزوجته (إن خرجت بغير إذني أو) إن خرجت (إلا بإذني أو) إن خرجت (حتى آذن لك أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة (أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم بالإذن) وخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها (أو خرجت) من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (تريد الحمام وغيره) أو عدلت منه إلى غيره (طلقت في الكل) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام (إلا إن أذن) لها (فيه) أي في الخروج (كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن (أو قال) لها إن خرجت (إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت) فلا حنث عليه %

8 فصل في تعليقه بالمشيئة

+ إذا علقه أي الطلاق (بمشيئتها ب إن أو غيرها من الحروف) أي الأدوات كإذا ومتى ومهما (لم تطلق حتى تشاء) فإذا شاءت طلقت (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق فإذا قيد المشيئة بوقت

كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به (فإن قالت) لمن قال لها إن شئت فأنت طالق (قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق) وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه لأن المشيئة أمر خفي لايصح تعليقه على الشرط (وإن

قال) لزوجته (إن شئت وشاء أبوك) فأنت طالق (أو) قال إن شئت وشاء (زيد) فأنت طالق (لم يقع) الطلاق (حتى يشاءا معا) أي جميعا فإذا شاءا وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي لأن المشيئة قد وجدت منهما (وإن شاء أحدهما) وحده (فلا) حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما (و) إن قال لزوجته (أنت طالق) إن شاء الله (أو قال عبدي حر إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشأ الله ونحوه (وقعا) أي الطلاق والعتق لأنه تعليق على مالا سبيل إلى علمه فيبطل كما لو علقة على شيء من المستحيلات (و) من قال لزوجته (إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل لأن الطلاق إذا يمين إذ هو تعليق على مايمكن فعله وتركه فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الترمذي وغيره (و) إن قال لزوجته (أنت طالق لرضى زيد أو) أنت طالق (لمشيئته طلقت في الحال) لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه (فإن قال أردت) بقولي لرضى زيد أو لمشيئته (الشرط) أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى (قبل حكما) لأن لفظه يحتمله لأن ذلك يستعمل للشرط وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة

من أخرس لا إن مات أو غاب أو جن قبلها (و) من قال لزوجته (أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى) حقيقة (رؤيتها) أي معاينتها إياه (لم تطلق حتى تراه) ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله (وإلا) ينو حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها) وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا % 9 فصل في مسائل متفرقة + (وإن حلف لايدخل دارا أو لايخرج منها فأدخل) الدار بعض جسده (أو أخرج) منها (بعض جسده) لم يحنث لعدم وجود الصفة إذا البعض لايكون كلا كما أن الكل لايكون بعضا (أو دخل) من حلف لايدخل الدار (طاق الباب) لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته (أو) حلف (لايلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها (أو) حلف (لايشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث) لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث لأن شرب جميعه ممتنع فلا تصرف إليه يمينه وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لايشرب الماء فيحنث ببعضه (وإن فعل المحلوف عليه)

مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا و (ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط) لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى (وإن فعل بعضه) أي بعض ما حلف لايفعله (لم يحنث إلا أن ينويه) أو تدل عليه قرينة كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر (وإن حلف) بطلاق أو غيره (ليفعلنه) أي شيئا عينه (لم يبرأ إلا بفعله كله) فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخة زيد وغيره حنث

باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

+ (ومعناه) أي معنى التأويل (أن يريد بلفظه ما) أي معنى (يخالف ظاهره) أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن (فإذا حلف وتأول) في (يمينه نفعه) التأويل فلا يحنث (إلا أن يكون ظالما) بحلفه فلا ينفعه التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على مايصدقك

به صاحبك رواه مسلم وغيره (وإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله) أي لزيد (عنده) أي عند الحالف (وديعة بمكان ف) حلف و (نوى غيره) أي غير مكانها أو نوى غيرها (أو) نوى (بما الذي) لم يحنث (أو حلف) من ليس ظالما بحلفه (مازيد هاهنا ونوى) مكانا (غير مكانه) بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث (أو حلف على امرأته لاسرقت مني شيئا نخانته في وديعة ولم ينوها) أي لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة (لم

يحنث في الكل) للتأويل المذكور ولأن الخيانة ليست سرقة فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث

5 باب الشك في الطلاق

+ أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه (من شك في طلاق أو) شك في شرطه) أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أم عدميا (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله قال الموفق والورع التزام الطلاق (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي للشك لأن الأصل عدم التحريم ويمنع من حلف لايأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به وإن لم تمنعه بذلك من الوطء (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه (وإلا) ينو معينة طلقت (من قرعت) لأنه لاسبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فشرعت

القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول (كمن طلق إحداهما) أي إحدى زوجتيه (بائنا ونسيها) فيقرع بينهما لما تقدم وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته (وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة المنسية (غير التي قرعت ردت إ ليه) أي إلى الزوج لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لايقبل قوله في إبطال حق غيره (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج (وإن قال) لزوجته (إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة) أي هند مثلا (طالق وإن كان حماما ففلانة) أي حفصة مثلا طالق (وجهل) الطائر (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة ولم يعلم وقع بإحدهما وتعين بقرعة (وإن قال لزوجته وأجنبيه اسمها هند إحداكما) طالق طلقت امرأته (أو) قال لهما (هند طالق

طلقت امرأته) لأنه لايملك طلاق غيرها وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته (وإن قال أردت الأجنبية) دين لاحتمال صدقه ولأن لفظه يحتمله و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بذل ظالما أو بتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله (وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب (وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق

6 باب الرجعة

+ وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد) بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد

دون ثنتين (فله) أي للمطلق حرا كان أو عبدا أولوية إذا كان مجنونا (رجعتها) مادامت (في عدتها ولو كرهت) لقوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقد بشرطه ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي وتحصل الرجعة (بلفظ راجعت امرأتي ونحوه) كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها و (لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها لأن ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية

(ويسن الإشهاد) على الرجعة وليس شرطا فيها لأنها لاتفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة وجملة ذلك أن الرجعة لاتفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها (وهي) أي الرجعية (زوجة) يملك منها مايملكه ممن لم يطلقها و (لها) ماللزوجات من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه (لكن لاقسم لها) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولها أن تتشرف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطؤها (وتحصل الرجعة أيضا بوطئها) ولو لم ينو به الرجعة (ولا تصح معلقة بشرط) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك بخلاف عكسه فيصح (فإذا طهرت) المطلقة رجعيا (من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها) روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض

المانع للزوج من الوطء فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم (وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد) بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ أي في العدة (ومن طلق دون مايملك) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة (ثم راجع) المطلقة رجعيا (أو تزوج) البائن (لم يملك) من الطلاق (أكثر مما بقي) من عدد طلاقه (وطئها زوج غيره أو لا) لأن وطء الثاني لايحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث %

1 فصل

+ (وإن ادعت) المطلقة (انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها) أي عدتها (فيه أو) ادعت انقضاء عدتها (بوضع الحمل الممكن وأنكره) أي أنكر المطلق انقضاء عدتها (فقولها) لأنه أمر لايعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه (وإن ادعته) أي انقضاء العدة (الحرة بالحيض في أقل من تسعة

وعشرين يوما ولحظة) أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر ولحظة (لم تسمع دعواها) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة وإلا فلا لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا (وإن بدأته) أي بدأت الرجعية مطلقها (فقالت انقضت) عدتي وقد مضى مايمكن انقضاؤها فيه (فقال) المطلق (كنت راجعتك) فقولها لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لاتقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل وكذا لو تداعيا معا ومتى رجعت قبل بجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به فإنه يقبل منه (أو بدأها به) أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك (فأنكرته) وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك (فقولها) قاله الخرقي قال في الواضح في الدعاوي نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع و المنتهى %

فصل

+ (إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين (حرمت عليه حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ بعد قوله ﴿ الطلاق مرتان ﴾ في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي (ولو) كان (مراهقا) أو لم يبلغ عشرا لعموم ماسبق (ويكفي) في حلها لمطلقها ثلاثا (تغييب الحشفة) كلها من الزوج الثاني (أو قدرها مع جب) أي قطع الحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك (في فرجها) أي قبلها (مع انتشار وإن لم ينزل) لوجود حقيقة الوطء (ولا تحل) المطلقة ثلاثا (بوطء دبر و) وطء ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ولا تحل بوطء (في حيض ونفاس وإحرام وصيام

(شبهة و) وطء في (ملك يمين و) وطء في (نكاح فاسد) لقوله تعالى ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ولا تحل بوطء في (حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض) لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى وتحل بوطء محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه (ومن ادعت مطلقته المحرمة) وهي المطلقة ثلاثا (وقد غابت) عنه (نكاح من أحلها) بوطئه إياها (و) ادعت (انقضاء عدتها منه) أي من الزوج الثاني (فله) أي للأول (نكاحها إن صدقها) فيما ادعته (وأمكن) ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها

كتاب الإيلاء

+ الإيلاء بالمد أي الحلف مصدر آلي يؤلي والألية اليمين (وهو) شرعا (حلف زوج) يمكنه الوطء (بالله تعالى أو صفته) كالرحمن الرحيم (على ترك وطء زوجته في قبلها) أبدا أو (أكثر من أربعة أشهر) قال تعالى

﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾ الآية وهو محرم ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء (ويصح) الإيلاء (من كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن و) بالغ و (مميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن) أي زوجة يمكن وطؤها ولو (لم يدخل بها) لعموم ما تقدم و (لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون ومغمى عليه) لعدم القصد (و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل) لأن المنع هنا ليس لليمين (فإذا قال) لزوجته (والله لاوطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر) كخمسة أشهر (أو) قال والله لاوطئتك (حتى ينزل عيسى) ابن مريم عليهما السلام (أو) حتى يخرج الدجال (أو) غياه بمحرم أو ببذل مالها

كقوله والله لاوطئتك (حتى تشربي الخمر أو تعطيني دينك أو تهبي مالك ونحوه) أي نحو ما ذكره (فهو مؤل) تضرب له مدة الإيلاء (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو) كان المؤلي (قنا) لعموم الآية (فإن وطىء ولو بتغييب حشفة) أو قدرها عند عدمها (فقد فاء) لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم لأن الوطء وجد (وإلا) يف بوطء من آلى منها ولم تعفه (أمره) الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه لقوله تعالى ﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ فإن أبى المؤلي أن يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ)

لقيامه مقام المؤلي عند امتناعه وكمؤل في هذه الأحكام من ترك الوطء ضرارا بلا عذر أو حلف أو ظاهر ولم يكفر (وإن وطىء) المؤلي من آلى منها (في الدبر أو) وطئها (دون الفرج فما فاء) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها (وإن ادعى) المؤلي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر صدق لأنه الأصل (أو) ادعى (أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه) لأنه أمر خفي لايعلم إلا من جهته (وإن كانت) التي آلى منها (بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك) أي ببكارتها (امرأة عدل صدقت) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه (وإن ترك) الزوج (وطأها) أي وطء زوجته (إضرارا بها بلا يمين) عل ترك وطئها (ولا عذر) له (فكمؤل) وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له أربعة أشهر فإن وطىء وإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المؤلي وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفي بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك ثم متى

قدر وطىء أو طلق ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام

16 كتاب الظهار

+ مشتق من الظهر وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ولذلك سمي المركوب ظهرا والمرأة مركوبة إذا غشيت (وهو محرم) لقوله تعالى ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ فمن شبه زوجته أو شبه (بعضها) أي بعض زوجته (ببعض) من تحرم عليه (أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب) كأمه وأخته (أو رضاع) كأخته منه أو بمصاهرة كحماته أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها (من ظهر) بيان للبعض كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي (أو) أنت علي ك (بطن) عمتي (أو عضو آخر لاينفصل) كيدها أو رجلها (بقوله) متعلق بشبه (لها) أي لزوجته (أنت) أو ظهرك أو يدك (علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام) فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا (أو) قال أنت علي (كالميتة والدم) الأجنبية أو كظهر أبي أو أخي أو زيد وإن قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار (

وإن قالته لزوجها) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) لقوله تعالى ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ﴾ فخصهم بذلك (وعليها) أي على الزوجة والخنزير (فهو مظاهر) جواب فمن وكذا لو قال أنت

علي كظهر فلانة إذا قالت ذلك لزوجها (كفارته) أي كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التفكير ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي (ويصح الظهار (من كل زوجة) لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين ولا يصح ممن لايصح طلاقه %

ج ٣ - ص ١٩٥

1 فصل

+ (ويصح الظهار معجلا) أي منجزا كأنت علي كظهر أمي (و) يصح الظهار أيضا (معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه (و) يصح الظهار (مطلقا أي غير مؤقت كما تقدم (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان (فإن وطىء فيه كفر) لظهاره (وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء ودواعيه) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها) لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به صححه الترمذي (ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي في ذمة المظاهر (إلا بالوطء) اختيارا (وهو) أي الوطء (العود) فمتى وطء لزمته الكفارة ولو مجنونا ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله يؤمر بها من أراده ليستحله بها (ويلزم إخراجها قبله) أي قبل الوطء (عند العزم عليه) لقوله تعالى في الصيام والعتق ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾ وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) كاليمين بالله تعالى (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره ظهار واحد (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي (ف) عليه (كفارات) بعددهن لأنها أيمان متكررة على

أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر % 2 فصل + (وكفارته) أي كفارة الظهار على الترتيب (عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا) لقوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾ من نسائه بكلمة واحدة)

بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي لأنه ظهار واحد (وإن ظاهر منهن) أى : من زوجاته (بكلمات) بأن قال لكل منهن : أنت على كظهر أمي (ف) عليه (كفارات) بعددهن ، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة ، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر .

فصل

(وكفارته) أى : كفارة الظهار على على الترتيب (عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين) فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، لقوله تعالى " 58 : 3 " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " . الآية والمعتبر في الكفارات وقت وجوب فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه (ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك) أي ملكها (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل لا بهبة ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها (فاضلا عن كفايته دائما و) عن (كفاية من يمونه) من زوجة ورقيق وقريب (و) فاضلا (عما يحتاجه) هو ومن يمونه (من مسكن وخادم) صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم (مال يقوم كسبه بمؤنته) ومؤنة عياله (وكتب علم) يحتاج إليها (ووفاء دين) لأن مااستغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم (ولا يجزئ في الكفارات كلها) ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار

رمضان واليمين بالله سبحانه (إلا رقبة مؤمنة) لقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ (ومركوب وعرض بذلة) يحتاج إلى استعماله (وثياب تجمل و)

فاضل عن ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ وألحق بذلك سائر الكفارات (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا) لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعها) أي اليد أو الرجل (أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام) أو أنملتين من وسطى أو سبابة (أو أقطع الخنصر والبنصر) معا (من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك وكذا أخرس لاتفهم إشارته (ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه) كزمن ومقعد لأنهما لايمكنهما العمل في أكثر الصنائع وكذا مغصوب (ولا) تجزئ (أم ولد) لأن عتقها مستحق بسبب آخر (ويجزئ المدبر) والمكاتب إذا لم يؤد شيئا (وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني) والصغير والأعرج يسيرا (والأمة الحامل ولو استثنى حملها) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل %

3 فصل

+ (يجب التتابع في الصوم) لقوله تعالى ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه (فإن تخلله رمضان) لم ينقطع التتابع (أو) تخلله (فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض) ونفاس (وجنون ومرض مخوف ونحوه) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع (أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر) كسفر (لم ينقطع) التتابع لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده (ولايجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد ولا من غيره) كالتمر والشعير (أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة ولو صغيرا لم يأكل الطعام والمد رطل وثلث بالعراقي وتقدم في الغسل (وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام بخلاف ما لو نذر إطعامهم ولايجزئ الخبز ولا القيمة وسن إخراج أدم مع مجزئ (وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية لحديث إنما الأعمال بالنيات ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة (وإن أصاب المظاهر منها) في أثناء الصوم (ليلا أو نهارا

) ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (انقطع التتابع) لقوله تعالى ﴿ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ﴾

ج ٣ - ص ١٩٩

وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها (ليلا) أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (لم ينقطع) التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه ولا هو محل التتابع ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه

17 كتاب اللعان

+ مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب (ويشترط لصحته أن يكون بين زوجين) مكلفين لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ فمن قذف أجنبية حد ولا لعان (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) لمخالفته للنص (وإن جهلها) أي العربية (فبلغته) أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها (فإذا قذف امرأته بالزنا) في قبل أو دبر ولو في طهر وطىء فيه (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة (باللعان) لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ الآيات (فيقول) الزوج (قبلها) أي قبل الزوجة (أربع مرات أشهد بالله

لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها) إن كانت حاضرة (ومع غيبتها بسميها وينسبها) بما تتميز به (و) يزيد (في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر بوقت ومكان معظمين وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة (فإن بدأت) الزوجة (باللعان قبله) أي قبل الزوج لم يصح (أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ) أي الجمل (الخمسة) لم يصح (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن لم يصح (أو أبدل) أحدهما (لفظة أشهد بأقسم أو أحلف) لم يصح (أو) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد) أو الغضب ونحوه لم يصح (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط لم يصح) اللعان لمخالفته النص وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات %

فصل

+ (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا)

ج ٣ - ص ٢٠١

قبله (ك) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ الآية (فإن قال) لزوجته (وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة أو نائمة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقة نسبه) لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش (ولا لعان) بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد (ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم) اللعان (سقط عنه) أي عن الزوج (الحد) إن كانت محصنة (والتعزير إن كانت غير محصنة (وتثبت الفرقة بينهما) أي بين الزوجين بتمام اللعان (بتحريم (مؤبد) ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسة بعد وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه كما لو هنىء به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها والتوأمان المنفيان أخوان لأم % 2 فصل فيما يلحق من النسب + (من ولدت زوجته من) أي ولدا (أمكن أنه منه لحقه) نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وإمكان كونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين (أو) تلده ل (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (وهو) أي الزوج (ممن يولد لمثله كابن عشر) لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر

ج ٣ - ص ٢٠٢

وفرقوا بينهم في المضاجع ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد (ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه) لأن الأصل عدمه وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا وإن لم يمكن كونه منه كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو لفوق أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه) أو ثبت عليه ذلك (فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه) نسب (ولدها) لأنها صارت فراشا له (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها (ويحلف عليه) أي على الاستبراء لأنه حق للولد لو لا دعواه لثبت نسبه (وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج أو فيه) أي في الفرج (ولم أنزل أو عزلت لحقه) نسبه لما تقدم (وإن عتقها) السيد (أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش

(لحقه) نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها أو بيعها حين كانت فراشا له (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له وإن كان استبراؤها لظهور أنه دم فساد لأن الحامل لاتحيض وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين وادعى مشتر أنه من بائع وإن استبرئت ثم ولدت لفوت نصف سنة لم يلحق بائعا ولا أثر لشبهة مع فراش وتبعية نسب لأب مالم ينفه بلعان وتبعية دين لخيرهما

18

كتاب العدد

+ واحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة (تلزم العدة كل امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها (فارقت زوجها) بطلاق أو خلع أو فسخ (خلا بها مطاوعة مع علمه بها و) مع (قدرته على وطئها

ولو مع ما يمنعه) أي الوطء (منهما) أي من الزوجين كجبه ورتقها (أو من أحدهما حسا) كجبه أو رتقها (أو) يمنع الوطء (شرعا) كصوم وحيض (أو وطئها) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق (وإن كان) النكاح (باطلا وفاقا) أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة (لم تعتد للوفاة) إذا مات عنها وإلا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد كعدمه (ومن فارقها) زوجها (حيا قبل وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لقوله تعالى ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ أو طلقها (بعدهما) أي بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها (بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطء مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة وكذا لو تحملت بماء قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو بشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة % 1 فصل + (والمعتدات ست) أي ستة أصناف أحدها (الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل) واحدا كان أو عددا حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة لقوله تعالى ﴿ وأولات

الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ وإنما تنقضي العدة غيره وجزم في المنتهى

في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (أو بوضع (ماتصير به أمة أم ولد) وهو ماتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لصغره أو لكونه ممسوحا أو) لكونها (ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بها (ونحوه) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر (لم تنقص به) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) لقوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه وقال تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ فإذا سقط الحولان اللذان ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء يلدن فيها (ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لافعل مايقطع حيضها من غير علمها %

2 فصل

+ (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل (قبل الدخول وبعده) يوطء مثلها أو لا (للحرة

أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها لقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون ﴾

هما مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل وذكر (سقط صفحة 208) منكم ﴿ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ وللأمة المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب (فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت) عده الطلاق (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) لأن الرجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث (وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة الوفاة وطلاق) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج أقلهما في أكثرهما

(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية أو) من جاءت البينونة منها ف) تعتد (لطلاق لا لغيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت لأنها أجنبية تحل للأزواج (وإن طلق بعض نسائه مبهمة) كانت (أو معينة ثم نسيها ثم مات) المطلق (قبل قرعة اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي عن عدة طلاق ووفاة لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة (الثالثة) من المتعدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم (المفارقة في الحياة) بطلاق أو خلع أو فسخ (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة) لقوله

تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ ولا يعتد بحيضة طلقت فيها (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرآن) روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم (الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر) لقوله تعالى ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ أي كذلك (و) عدة (أمة) كذلك (شهران) لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين رواه الأثرم واحتج به أحمد (و) عدة (مبعضة بالحساب) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث قدر ما فيها من الحرية (ويجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام (الخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي سبب رفعه (فعدتها) إن كانت حرة (سنة تسعة أشهر للحمل) لأنها غالب مدته (وثلاثة) أشهر (للعدة) قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لاينكره منهم منكر علمناه ولاتنقض العدة بعود الحيض بعد المدة (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) فعدتها أحد عشر شهرا (وعده من بلغت ولم تحض) كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى ﴿ واللائي لم يحضن ﴾ و عدة (المستحاضة الناسية) لوقت حيضها كآيسة (و) عدة (المستحاضة المبتدأة) الحرة (ثلاثة أشهر والأمة شهران) لأن غالب النساء يحضن في

كل شهر حيضة (وإن علمت) من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد

به) وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم (أو تبلغ سن الإياس) خمسين سنة (فتعتد عدته) أي عدة الإياس أي عدة ذات الإياس ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا (السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود تتربص) حرة كانت أو أمة (ماتقدم في ميراثه) أي أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة (ثم تعتد للو فاة) أربعة أشهر وعشرة أيام (وأمة) فقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين أو تسعين سنة (و) أما (في العدة) للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها (نصف عدة الحرة) لما تقدم (ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم

بضرب المدة) أي مدة التربص (وعدة الوفاة) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها (وإن تزوجت) زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة (فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد (و) إن الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني ف (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني وله) أي للأول (تركها معه) أي مع الثاني (من غير تجديد عقد) للثاني وقال المنقح الأصح بعقد اه قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك اه وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا لأن زوجة الإنسان لاتصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو (ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته ومتى فرق بين زوجين لموجب تم بان انتفاؤه فكمفقود %

3 فصل

+ (ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت

لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو) موطوءة (بعقد فاسد كمطلقة) حرة كانت أو أمة مزوجة لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج (وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما) أي بين المعتدة الموطوءة والواطىء (وأتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول (ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه (ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك (وتحل) الموطوءة في عدتها بشبهة

أو نكاح فاسد (له) أي لوطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدتين) لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب (وإن تزوجت) المعتدة (في عدتها لم تنقطع) عدتها (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا (فإذا فارقها) الثاني (بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني) لما تقدم (وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه (انقضت منه عدتها به) أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ويكون للثاني أذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول وإن أشكل عرض على القافة (ومن وطئ معتدته البائن) في عدتها (بشبة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها

ثم طلقها استأنفت (وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت) على مامضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول %

4 فصل

+ يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج (ويلزم الإحداد مدة العدة كل) امرأة (متوفى عنه زوجها في نكاح صحيح) لقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها (ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة) فيجنبها وليها الطيب ونحوه وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات (ويباح) الإحداد (لبائن من حي) ولايسن لها قاله في الرعاية (ولا يجب)

الإحداد (على) مطلقة (رجعية) و لاعلى (موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو) نكاح (باطل أو ملك يمين) لأنها ليست زوجة متوفى عنها (والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين) باسفيداج ونحوه (والحناء وما صبغ للزينة) قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين (و) ترك (حلي وكحل أسود) بلا حاجة (لاتوتياء ونحوها ولا) ترك (نقاب و) لاترك (أبيض ولو كان حسنا) كإبريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا من أخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل %

5 فصل

+ (وتجب عدة الوفاة في المنزل) الذي مات زوجها وهي به (حيث وجبت) فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة (فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها (أو) حولت (قهرا أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها

أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها (انتقلت حيث شاءت) للضرورة ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت (ولها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا) لأنه مظنة الفساد (وإن تركت الإحداد) عمدا (أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها) أي زمان العدة لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها وتعتد بائن بمأمون من البلد بحيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها

1 باب الاستبراء

+ مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (من ملك أمة يوطأ مثلها) ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك (من صغير وذكر وضدهما) وهو الكبير والمرأة (حرم عليه وطؤها ومقدماته) أي مقدمات الوطء من قبله ونحوها (قبل استبرائها) لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود

وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها فإن خالف صح البيع دون التزويج وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها (واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (و) استبراء (من تحيض بحيضة) لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر وتصدق الأمة إن قالت حضت وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها

19 كتاب الرضاع

+ وهو لغة مص اللبن من الثدي وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لحديث عائشة

مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة (والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات) لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وتحرم الخمس إذا كانت (في الحولين) لقوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث حسن صحيح ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة فإن عاد ولو

قريبا فثنتان (والسعوط) في أنف (والوجور) في فم محرم كرضاع (ولبن) المرأة (الميتة) كلبن الحية (و) لبن (الموطوءة بشبهة أو عقد فاسد)

كالموطوءة بنكاح صحيح (أو باطل) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا (أو بزنا محرم) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ماهو فرعها (وعكسه) أي عكس اللبن المذكور لبن (البهيمة و) لبن (غير حبلى ولا موطوءة) فلا يحرم فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين (فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح و) إباحة (النظر والخلوة و) في (المحرمية) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها (و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (ولد من نسب لبنها إليه بحمل) أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه (أو وطئ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك (و) صارت (محارمه) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخواته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته (محارمه) أي محارم المرتضع (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم (محارمه) أي محارم المرتضع (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لآولئك (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب و)

تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعا (كما يحل لأخيه من أبيه) أخته من أمه (ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وجدته وأخته (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة (وكل أمرأة أفسدت نكاح نفسها ب) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها) لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لافعل للزوج في الفسخ (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول فمهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول لأنه لافعل لها في الفسخ (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول لاستقراره به (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) لأنه أغرمه فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة (ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح) حكما لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينها فلزمه ذلك (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (وإن أكذبته) في قوله أنها أخته قبل الدخول (فلها نصفه) أي نصف

المسمى لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (ويجب) المهر (كله) إذا كان إقراره

بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا لأن قولها لايقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا (وإذا شك في الرضاع أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعات (أو شكت المرضعة) في ذلك (ولا بينة فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء

20

+ جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا) أي خبزا وإداما (وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها) لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي بيسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر (عند

التنازع) بينهما (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر قدر كفايت من أرفع خبز البلد وأدمه و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بمحلهما و) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة (ما يلبس مثلها من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء (وللنوم فراش ولحاف وإزار) للنوم في محل جرت العادة فيه (ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي) أي بساط ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها (و) يفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد و) من (أدم يلائمه) وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر (و) يفرض للفقير من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه و) يفرض (للمتوسطة والغنية مع الفقير وعكسها) كفقيرة تحت غني (ما بين ذلك عرفا) لأن ذلك هو اللائق بحالهما (وعليه)

أي على الزوج (مؤنة نظافة زوجته) من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة (دون) ما يعود بنظافة (خادمها) فلا يلزمه لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم

(ولا) يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة وأتى به لزمها وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة لحاجة %

1 فصل

+ (ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم (والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض (لها ذلك) أي النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) لقوله تعالى ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبن رجع (والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز

ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو أعتقها وتسقط بمضي الزمان قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع (ومن) أي أي زوجة (حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو) نذر (صوم أو صامت عن كفارة أو) عن (قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت مما أوجب الشرع عليها وقدرها في حجة فرض كحضر وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها

(ولا نفقة ولا سكنى) من تركة (المتوفى عنها) ولو حاملا لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت وإلا فعلى وارثه الموسر (ولها) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها (أخذ نفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه والواجب دفع قوت من خبز وأدم لاحب و (لاقيمتها) أي قيمة النفقة (ولا) يجب (عليها أخذها) أي أخذ قيمة النفقة لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كالدارهم إلا بتراضيهما (فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة (أو) اتفقا (على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) لأن الحق لايعدوهما (ولها الكسوة كل

عام مرة في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار ابن نصر الله أنها كماعون ومشط تجب بقدر الحاجة ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد (فإذا غاب) الزوج أو كان حاضرا (ولم ينفق) على زوجته (لزمته نفقة ما مضى) وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة (وإن أنفقت) الزوجة (غيبته) أي غيبة الزوج (من ماله فبان ميتا غرمها الوارث) للزوج (ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله %

2 فصل

+ (ومن تسلم زوجته) التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها (أو بذلت) تسليم (نفسها) أو بذله وليها (ومثلها يوطأ) بأن تم لها تسع سنين (وجبت نفقتها) وكسوتها (ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته) ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي لأن النفقه كأرش جناية ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى براسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (ولها) أي الزوجة

(منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه يحق (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه) ولا نفقة لها مدة الامتناع وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم تطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت أو) أعسر) بالكسوة) أي كسوة المعسر (أو) أعسر ب (بعضها) أي بعض نفقة المعسر أو كسوته (أو) أعسر ب (المسكن) أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح) من زوجها المعسر لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولايحبسها (فإن غاب) زوج (موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها

من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم) لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفايه ولدها وخادمها بالمعروف

ج ٣ - ص ٢٣٤

بلا إذنه فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله

1 باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم

+ (تجب) النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك

شيئا (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض (لأبويه وإن علوا) لقوله تعالى ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما (و) تجب النفقة أو تتمتها (لولده وإن سفل) ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ حتى ذوي الأرحام منهم أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كولد البنت سواء (حجبه) أي الغني (معسر) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر (أولا) بأن لم يحجبه أحد كمن له معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه (و) تجب النفقه أو كمالها ل (كل من يرثه) المنفق (بفرض) كولد لأم (أو تعصيب) كأخ وعم لغير أم (لا) لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (سوى عمودي نسبه) كما سبق (سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أو لا كعمة وعتيق) وتكون النفقة على من تجب عليه (بمعروف) لقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ ثم قال ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث وروى

أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه وتقدمت الإشارة إليه الثاني فقر المنفق عليه وقد أشار إليه بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن تكسب) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفه له الثالث غني المنفق وإليه الإشارة بقوله (إذا فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه (من حاصل) في يده (أو متحصل) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف

ونحوه لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته و (لا) تجب نفقة القريب (من رأس مال) التجارة (و) لا من (ثمن ملك و) لامن (آلة صنعة) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه (ومن له وارث غير أب) واحتاج للنفقة (فنفقته عليهم) أي على وارثيه (على قدر إرثهم) منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث (ف) من له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلث والثلثان على الجد) لأنه لو مات لورثاه كذلك (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس والباقي على الأخ) لأنهما يرثانه كذلك (والأب ينفرد بنفقة ولده) فقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما) أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن (ومن) احتاج لنفقة و (أمة فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة) ليسارها ولا يمنع ذلك

حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم (ومن عليه نفقة زيد) مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه (فعليه نفقة زوجته) لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه (ك) نفقة (ظئر) من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليهما (لحولين) كاملين لقوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ إلى قوله ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ والوارث إنما يكون بعد موت الأب (ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا (إلا بالولاء) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه (و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده) إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ أي فاسترضعوا له أخرى (ويؤدي الأجرة) لذلك لأنها في الحقيقه نفقة لتولد اللبن من غذائها (ولا يمنع) الأب (أمه إرضاعه) أي إرضاع ولدها لقوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان (ولا يلزمها) أي لا يلزم الزوجه إرضاع ولدها دنيئة كا نت أو شريفة لقوله تعالى ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ إلا لضرورة نكوف تلفه أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه لأنه إنقاذ أي للمرضعة (طلب أجرة المثل) لرضاع ولدها (ولو أرضعه غيرها مجانا) لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ (بائنا كانت)

أم الرضيع في الأحوال المذكورة (أو تحته) أي زوجة لأبيه لعموم قوله تعالى ﴿ فإن أرضعن ﴾ من هلكة

ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن (ولها) ﴿ لكم فآتوهن أجورهن ﴾ وإن تزوجت المرضعة (آخر فله) أي للثاني (منعها من إرضاع ولد الأول ما لم) تكن اشترطته في العقد أو (يضطر إليها) بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم %

1 فصل في نفقة الرقيق

+ (و) يجب (عليه) أي على السيد (نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا (طعاما) من غالب قوت البلد (وكسوة وسكنى) بالمعروف (وأن لايكلفه مشقا كثيرا) لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من

العمل مالا يطيق رواه الشافعي في مسنده (وإن اتفقا على المخارجة) وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له (جاز) إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم (ويريحه) سيده (وقت القائلة) وهي وسط النهار (و) وقت (النوم و) وقت الصلاة (المفروضة) لأن عليهم في ترك ذلك ضررا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار (ويركبه) السيد (في السفر عقبه) لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق (وإن طلب) الرقيق (نكاحا زوجه) السيد (أو باعه) لقوله تعالى ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ وإن طلبته أي التزويج أمة (وطئها) السيد (أو زوجها أو باعها) إزالة لضرر الشهوة عنها ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطء

وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح ويقيده إن خاف إباقه ولا يشتم أبويه ولو كافرين ولا يلزمه بيعه بطلبه

مع القيام بحقه وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ولا يتسرى عبد مطلقا %

2 فصل في نفقة البهائم

+ (و) يجب (عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها) لقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه (و) يجب عليه (أن لا يحملها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له

كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه (ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها) لقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت) لأن بقاءها في يده مع ترك

الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته فإن أبى فعل حاكم الأصلح ويكره جز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو حمارعلى فرس وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان

2 باب الحضانة

+ من الحضن وهو الجنب لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه (تجب) الحضانة

(لحفظ صغير ومعتوه) أي مختل العقل (ومجنون) لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة (والأحق بها أم) لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أبو داود ولأنها أشفق عليه (ثم أمهاتها القربى فالقربى) لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن (ثم أب) لأنه أصل النسب (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة (ثم جد) كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحضون (ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى (ثم أخت لأبوين) لتقدمها في الميراث (ثم) أخت (لأم) كالجدات (ثم) أخت (لأب ثم خالة لأبوين ثم) خالة (لأم ثم) خالة (لأب) لأن الخالات يدلين بالأم (ثم عمات كذلك) أي تقدم العمة لأبوين ثم لأب ثم لأم لأنهن يدلين بالأب (ثم خالات أمة) كذلك (ثم خالات أبيه) كذلك (ثم عمات أبيه) كذلك ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأنهن يدلين بأبي الأم

وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات (ثم بنات إخوته) تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم ثم بنت أخ لأب (و) مثلهن بنات (أخواته ثم بنات أعمامه) لأبوين ثم لأم ثم لأب (و) بنات (عماته) كذلك (ثم بنات أعمام أبيه) كذلك على التفصيل المتقدم (ثم) تنتقل (لباقي العصبة الأقرب فالأقرب) فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذا (فإن كانت) المحضونة (أنثى ف) يعتبر أن يكون العصبة (من محارمها) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها (ثم) تنتقل الحضانة (لذوي أرحامه) من الذكور والإناث غير من تقدم وأولاهم أبو أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال (ثم) تنتقل (للحاكم) لعموم ولايته (وإن امتنع من له الحضانة) منها (أو كان) من له الحضانة (غير أهل) للحضانة (انتقلت إلى من بعده) يعني إلى من يليه كولاية النكاح لأن وجود غير المستحق كعدمه (ولا حضانة لمن فيه رق) ولو قل

لأنها ولاية وليس هو من أهلها (ولا) حضانة (لفاسق) لأنه لايوثق به فيها ولا حظ للمحضون في حضانته (ولا) حضانة (لكافر) على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق (ولا) حضانة (لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد) للحديث السابق ولو رضي زوج (فإن زال المانع) بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو راجعيا (رجع إلى حقه) لوجود السبب وانتفاء المانع (وإن أراد

أحد أبويه) أي أبوي المحضون (سفرا طويلا) لغير الضرار قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم (إلى بلد بعيد) مسافة قصر فأكثر (ليسكنه وهو) أي البلد (وطريقه آمنان فحضانته) أي المحضون (لأبيه) لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع (وإن بعد السفر) وكان (لحاجة) لا لسكنى فمقيم منهما أولى (أو قرب) السفر (لها) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارا به (أو) قرب السفر وكان (للسكنى ف) الحضانة (لأمه) لأنها أتم شفقة وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره

فصل

(وإذا بلغ الغلام سبع سنين) كاملة (عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما) قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وروى سعيد

والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه فإن أختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول نقل إليه وهكذا فإن لم يختر أو اختارهما أقرع (ولا يقر) محضون (بيد من لايصونه ويصلحه) لفوات المقصود من الحضانة (وأبو الأنثى أحق بها بعد) أن تستكمل (السبع ويكون الذكر بعد) بلوغه و (رشده حيث شاء) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد ويستحب له أن لايفرد عن أبويه (والأنثى) منذ يتم لها سبع سنين (عند أبيها) وجوبا (حتى يتسلمها زوجها) لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت قاله الشيخ تقي الدين وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لاتعمل مصلحتها بل تؤذيها و تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الإنفراد والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا

كتاب الجنايات

+ جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبولة (وهي) أي الجناية ثلاثة أضرب (عمد

يختص القود به) والقود قتل القاتل بمن قتله (بشرط القصد) أي قصد الجاني الجناية (و) الضرب الثاني (شبه عمد و) الثالث (خطأ) روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما (ف) القتل (العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به) فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا وللعمد تسع صور إحداها ما ذكره بقوله (مثل أن يجرحه بما له مور) أي نفوذ (في البدن) كسكين وشوكة ولو بغرزة بإبرة ونحوها ولو لم يداو مجروح قادر جرحه الثانية

أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله (أو بضربه بحجر كبير ونحوه) كلت وسندان ولو في غير مقتل فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد 2 إلا إن كان في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به (أو يلقي عليه حائطا) أو سقفا ونحوهما (أو يلقيه من شاهق) فيموت الثالثة أن يلقيه بحجر أسد أو نحوه أو مكتوفا بحضرته أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا الرابعة ما أشار إليه بقوله (أو يلقيه (في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما) لعجزه أو كثرتهما فإن أمكنه

قدر الخامسة ما ذكرها بقوله (أو بخنقه) بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله السادسة أشار إليها بقوله (أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا) بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر السابعة ما أشار إليها بقوله (أو يقتله بسحر) يقتل غالبا الثامنة المذكورة في قوله (أو) يقتله

(بسم) بأن سقاه سما لايعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل التاسعة المشار إليها بقوله (أوشهدت عليه بينة بما يوجب قتله) من زنا أو ردة لاتقبل معها التوبة أو قتل عمد (ثم رجعوا) أي الشهود بعد قتله (وقالوا عمدنا قتله) فيقاد بهذا كله (ونحو ذلك) لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولي عالم بذلك وبينة وحاكم علموا ذلك (وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة) ونحوها (أو لكزه ونحوه) بيده أو ألقاه في ماء قليل أو صاح بعاقل اغتفله

أو بصغير على سطح فسقط فمات (و) قتل (الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو) يرمي (غرضا أو) يرمي (شخصا) مباح الدم كحربي وزان محصن (فيصيب آدميا) معصوما (لم يقصده) بالقتل فيقتله وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله (و) كذا (عمد الصبي والمجنون) لأنه لاقصد لهما كالمكلف المخطئ فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته كما سيأتي ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف

علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ سورة النساء من الآية (92) ولم يذكر الدية %

1 فصل

+ (تقتل الجماعة) أي اثنان فأكثر (ب) الشخص (الواحد) إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص مالم يتواطأوا عليه (وإن سقط القود) بالعفو عن القاتلين (أدوا دية واحدة) لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فهما سواء وإن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني (ومن أكره مكلفا على قتل) معين (مكافئه فقتله بالقتل) أي القود إن لم يعف وليه (أو الدية) إن عفا (عليهما) أي على القاتل ومن أكرهه لأن

القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه (وإن أمر) مكلف (بالقتل غير المكلف) كصغير أو مجنون فالقصاص على الأمر لأن المأمور آلة له لايمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به (أو) أمر مكلف بالقتل (مكلفا يجهل تحريمه) أي تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآ مر فالقصاص على الآمر لما تقدم (أو أمر به) أي بالقتل (السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه) أي في القتل

بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل (فقتل) المأمور (فالقود) إن لم يعف مستحقه (أو الدية) إن عفا عنه (على الآمر) بالقتل دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق (وإن قتل المأمور) من السلطان أو غيرة (المكلف) حال كونه (عالما بتحريم القتل فالضمان عليه) بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر لقوله صلى الله عليه وسلم لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق (دون الآمر) بالقتل فلا ضمان عليه لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء (وإن اشترك فيه) أي في القتل (اثنان لايجب القود على أحدهما) لو كان (منفردا لأبوة) للمقتول

(أو غيرهما) من إسلام أو حرية كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر ورقيق في قتل رقيق أو مسلم وكافر في قتل كافر (فالقود على الشريك) للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل العمد العدوان وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لالقصور في السبب بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي

أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص (فإن عدل) ولي القصاص (إلى طلب المال) من شريك الأب ونحوه (لزمه نصف الدية) كالشريك في إتلاف مال وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول

1 باب شروط وجوب القصاص

+ (وهي أربعة) أحدها (عصمة المقتول) بأن لايكون مهدر الدم (فلو قتل مسلم) حربيا أو نحوه (أو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيا أو مرتدا) أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم (لم يضمنه بقصاص ولا دية) ولو أنه مثله الشرط (الثاني التكليف) بأن يكون القاتل بالغا عاقلا لأن القصاص عقوبة مغلظة (فلا) يجب (قصاص على صغير ولا مجنون) أو معتوه لأنه ليس لهم قصد صحيح الشرط (الثالث المكافأة) بين المقتول وقاتله حال جنايته (بأن يساويه) القاتل (في الدين والحرية والرق) يعني بأن لايفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك (فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر)

كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود (ولا) يقتل (حر بعبد) لحديث أحمد عن علي من السنه أن لا يقتل حر بعبد وروى الدارقطني عن ابن عباس برفعه لايقتل حر بعبد وكذا لايقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته (وعكسه) بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا (يقتل) القاتل ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل

بالدميم والشريف بضده (ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر) والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الشرط (الرابع عدم الولادة) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت (فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم (ويقتل الولد بكل منهما) أي من الأبوين وإن علوا لعموم قوله تعالى ﴿ كتب عليكم القصاص ﴾ وخص منه ما تقدم بالنص ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض

باب استيفاء القصاص

+ وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه (يشترط له) أي لاستيفاء القصاص (ثلاثة شروط) (أحدها كون مستحقه مكلفا) أي بالغا عاقلا (فإن كان) مستحق القصاص أو بعض مستحقه (صبيا أو مجنونا لم يستوفه) لهما أب ولا وصي ولا حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره (وحبس الجاني) مع صغر مستحقه (إلى البلوغ و) مع جنونه إلى (الإفاقة) لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية

(الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه) أي في القصاص (على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه (وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم) للغائب (والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط ولشريك في تركة جان حقه من الدية ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه وإن عفا بعضهم سقط القود الشرط (الثالث أن يؤمن) في (الاستيفاء أن يتعدى الجاني) إلى غيره

لقوله تعالى ﴿ فلا يسرف في القتل ﴾ فإذا وجب القصاص (على) امرأة حامل أو امرأة (حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ) لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره لأنه في الغالب لايعيش إلا به (ثم) بعد سقيه اللبأ (إن وجد من برضيه) أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه (وإلا) يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه) لحولين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت امرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإذا زنت لم ترجم حتى تضع مافي بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها رواه ابن ماجه (ولا يقتص منها) أي من الحامل (في طرف) كاليد والرجل (حتى تضع) وإن لم تسقه اللبأ (والحد) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت (في ذلك كالقصاص) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع %

1 فصل

+ (ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف (و) لايستوفى إلا (بآلة ماضية) وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل وينظر في الولي فإن

كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل وإن تحتاج إلى أجرة فمن مال جان (ولا يستوفى) القصاص (في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره) لقوله صلى الله عليه وسلم لاقود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف

باب العفو عن القصاص

+ أجمع المسلمون على جوازه (يجب ب) القتل (العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما) لحديث أبي هريره مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير

النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل رواه الجماعة إلا الترمذي (وعفوه) أي عفو ولي القصاص (مجانا) أي من غير أن يأخذ شيئا (أفضل) لقوله تعالى ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ ولحديث أبي هريرة مرفوعا ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا رواه أحمد ومسلم والترمذي ثم لاتعزير على جان (فإن اختار) ولي الجناية (القود أو عفا عن الدية فقط) دون القصاص (فله أخذها) أي أخذ الديه لأن القصاص أعلا فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى (و) له (الصلح على أكثر منها) أي من الدية وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا (وإن اختارها) أي اختار الدية فليس له غيرها فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص (أو عفا مطلقا) بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم (أو هلك الجاني فليس له) أي لولي الجناية (غيرها) أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه (وإذا قطع) الجاني (أصبعا العفو على غير شيء ف) السراية (هدر) لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى (وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي (وإن وكل) ولي الجناية (من يقتص) له (ثم عفا) الموكل عن القصاص (فاقتص وكيله ولم يعلم) بعفوه (

فلا شيء عليهما) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو و ﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾ ولا على عمدا

فعفا) المجروح (عنها ثم سرت) الجناية (إلى الكف أو النفس وكان الوكيل لأنه لاتفريط منه وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه (وإن وجب لرقيق قود أو) وجب له (تعزير قذف فطلبه) إليه (وإسقاطه إليه) أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به (فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه من الأطراف والجراح + (من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (أقيد به في الطرف والجراح) لقوله تعالى ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الآية (ومن لا) يقاد أحق به ممن ليس له فيه ملك

باب مايوجب القصاص فيما دون النفس

(سقط صفحة 272) بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده (فلا) يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة (ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان) (أحدهما في الطرف فتؤخذ العين) بالعين (والأنف) بالأنف (والأذن) بالأذن (والسن) بالسن (والجفن) بالجفن (والشفة) بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى (واليد) باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى (والرجل) بالرجل كذلك (والأصبع) بأصبع تماثلها في موضعها (والكف) بالكف المماثلة (والمرفق) بمثله (والذكر والخصية والألية والشفر) بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم (كل واحد من ذلك بمثله) للآية السابقة (وللقصاص في الطرف شروط) ثلاثة (الأول الأمن من الحيف) وهو شرط جواز الاستيفاء ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف

(بأن يكون القطع من مفصل أو) له حد (ينتهي إليه) يعني إلى حد (كمارن الأنف وهو مالان منه) دون القصبة فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة الشرط (الثاني المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين) من يد ورجل وعين وأذن ونحوها (بيسار ولا يسار بيمين ولا) يؤخذ (خنصر ببنصر ولا) عكسه لعدم المساواة في الاسم ولا يؤخذ (أصلي بزائد وعكسه) فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة (ولو تراضيا) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه (لم يجز) أخذه

به لعدم المقاصة ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه (في الصحة والكمال فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة ب) يد أو رجل (شلاء ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتهما) (ولا) تؤخذ (عين صحيحة ب) عين (قائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك (ويؤخذ عكسه) فتؤخذ الشلاء ناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة (ولا أرش) لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولاتوخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء ومارن الأخشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء لأن ذلك لعلة في الدماغ %

1 فصل

+ (النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس (الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة وذلك (كالموضحة) في الرأس والوجه (وجرح العضد و) جرح (الساق و) جرح (الفخذ و) جرح (القدم) لقوله تعالى ﴿ والجروح قصاص ﴾ ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة (و) لا في غير ذلك من (الجروح) كالجائفة لعدم

أمن الحيف والزيادة ولا يقتص في كسر عظم (غير كسر سن) لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه (إلا أن يكون) الجرح (أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله) أي للمجني عليه (أن يقتص موضحة) لأنه يقتصر على بعد حقه ويقتص من محل جنايته (وله أرش الزائد) على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرة وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ويعتبر قدر جرح بمساحة دون

كثافه اللحم (وإذا قطع جماعة طرفا) يوجب قودا كيد (أو جرحوا جرحا يوجب القود) كموضحة ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت (فعليهم) أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين (القود) لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقه فقطع يده ثم جاء آخر فقالا هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وإن تفرقت أفعالم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم (وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها) فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود فيما يشل الأرش بقود أو دية (وسراية القود مهدورة) فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كآلئة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية (ولا) يجوز أن (يقتص عن عضو وجرح قبل برئه) لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني (وكما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه لاحتمال السراية فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة فلو مات تعينت دية الذاهب

كتاب الديات

+ جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته (كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفرها أو وضع حجرا

أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك (لزمته ديته) سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا لقوله تعالى ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ﴾ فإن كانت الجناية (عمدا محضا ف) الدية (في مال الجاني) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لاعذر له فلا يستحق التخفيف وتكون (حالة) غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات (و) دية (شبه العمد والخطأ على عاقلته) أي عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الآخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية)

فمات (أو أصابته صاعقة) و هي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فمات وجبت الدية (أو مات بمرض) وجبت الدية جزم به في الوجيز و منتخب الآدمي وصححه في التصحيح وعنه لا دية عليه نقلها أبو الصقر وجزم بها

في المنور وغيره وقدمها في المحرر وغيره قال في شرح المنتهى على الأصح وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى و الإقناع (أو غل حرا مكلفا

وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية) لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه

فصل

+ (وإذا أدب الرجل ولده) ولم يسرف لم يضمنه وكذا لو أدب زوجته في نشوز (أو) أدب (سلطان رعيته أو) أدب (معلم صبية ولم يسرف يضمن ما تلف به) أي بتأديبه لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه ومن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا يعقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه (ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب) بالغرة لسقوطه بتعديه (وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله) تعالى

فأسقطت (أو استعدى عليها رجل) أي طلبها لدعوى عليها (بالشرط في دعوى له فأسقطت) جنينا (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى لهلاكها بسببه (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية لهلاكه بسببه (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع أولا (لم يضمنا) أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الكافي وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره وقطع به في المنتهى وغيره ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة (ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل (فهلك به) أي بنزوله أو صعوده (لم يضمنه) الآمر (ولو أن الآمر سلطان) لعدم إكراه له وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجن ولم يتعد عليه وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح

باب مقادير ديات النفس

+ المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره (دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة) لحديث أبي داود عن جابر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو داود وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار (هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها

(فأيها أحضر من تلزمه) الدية (لزم الولي قبوله) سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه ثم تارة تغلظ الدية وتارة لاتغلظ (فتغلظ في قتل العمد وشبهه) فيؤخذ (خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة) ولا تغليظ في غير إبل (و) تكون الدية (في الخطأ) مخففة ف (تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) هذا قول ابن مسعود وكذا حكم الأطراف وتؤخذ من بقر مسناة وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياة دية نقد لاطلاق الحديث السابق بل تعتبر فيها السلامة من العيوب لأن الاطلاق يقتضي السلامة (ودية) الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن (نصف دية المسلم) لحديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل

الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد وكذا جراحه (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد أو المستأمن (و) دية (الوثني) المعاهد أو المستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة (ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم (ك) ديه نساء (المسلمين) لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما (ودية قن) ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا (قيمته) عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس (و) في (جراحه) أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر وفي أنفه قيمته كاملة وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه وإن لم يقدر من حر ضمن ب (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناتيه على

أمه عمدا أو خطا (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما (و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة)

ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فأكثر ففيه إذا مات ما فيه مولودا وفي جنين دابة مانقص أمه (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة (أو) جنى عمدا (ففيه قود واختير فيه المال أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن السيد تعلق) ما وجب ب (ذلك برقبته) لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجنايه فيملكه أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله وإن جنى عمدا فعفا ولي ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه

باب ديات الأعضاء ومنافعها

+ أي منافع الأعضاء (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه) (واللسان والذكر) ولو من صغير (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي

الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية رواه أحمد والنسائي واللفظ له (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين) ولو مع حول أو عمش (و) ك (الأذنين) ولو لأصم (و) ك (الشفتين و) ك (اللحيين) وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان (وكثديي المرأة وكثندوتي الرجل) بالثاء المثلثة فإن ضممتها همزت وإن فتحتها لم تهمز وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة (و) ك (اليدين والرجلين والإليتين وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها (ففيهما الدية وفي إحدهما نصفها)

أي نصف الدية لتلك النفس (وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها) لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها (وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) لحديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع رواه الترمذي وصححه (وفي كل أنملة) من أصابع اليدين أو الرجلين (ثلث عشر الدية) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل (والإبهام) فيه (مفصلان وفي كل مفصل) منها (نصف عشر الدية كدية السن) يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمسا من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل رواه النسائي %

1 فصل في دية المنافع

+ (و) تجب (في كل حاسة دية كاملة وهي) أي الحواس (السمع والبصر والشم والذوق) لحديث وفي السمع الدية ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح

و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة (و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي) أي الشعور الأربعة (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين وأهداب العينين) روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وفي الشعر الدية ولأنه أذهب الجمال على الكمال وفي حاجب نصف الدية وفي هدب ربعها وفي شارب حكومة (فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور (فنبتت سقط موجبه) فإن كان أخذ شيئا رده وإن ترك من لحية أو غيرها مالا جمال فيه فدية كاملة (و) تجب (في عين الأعور

الدية كاملة) قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر لم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية (وإن قلع ألاعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور وهو إنما أذهب بصر عين واحدة وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه

باب الشجاج وكسر العظام

+ الشج القطع ومنه شججت المفازة أي قطعتها (الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة) سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة فإن كان في غيرهما سمي جرحا لاشجة (وهي) أي الشجة باعتبار باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب (عشر) مرتبة أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لايسيل منه دم والحرص الشق يقال حرص القصار الثوب إذا شقة قليلا وتسمى أيضا القاشرة والقشرة (ثم) يليها (البازلة الدامية الدامعة) بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين (وهي التي يسيل منها الدم ثم) يليها (الباضعة وهي التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد ومنه سمي البضع (ثم) يليها (المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه (ثم) يليها (السمحاق وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمى السمحاق سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل) فيها (حكومة) لأنه لاتوقيف فيها في الشرع فكانت كجراحة بقية البدن (وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم) هكذا في خطه والصواب العظم (وتبرزه) عطف تفسير على توضحه

ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره (خمسة أبعرة) لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان (ثم) يليها (الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه) أي تكسره (وفيها عشرة أبعرة) روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة (ثم) يليها (المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل) لحديث عمرو بن حزم (وفي كل واحدة من المأمومة) وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ (والدامغة) بالغين المعجمة وهي التي تخزق الجلدة (ثلث الدية) لحديث عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده فوصل إلى فمه فحكومة كما لو أدخل غير زوج أصبعه في فرج بكر (وفي الجائفة ثلث الدية) لما في كتاب عمرو بن حزم في الجائفة ثلث الدية (وهي) أي الجائفة (التي تصل إلى بطن الجوف) كبطن ولو لم تخرق أمعاء وظهر وصدر ومثانة وبين خصيتين ودبر وإن أدخل السهم من جانب فخرج من الأخر

فجائفتان رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر ومن وطئ زوجة لايوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول وإلا فثلثها وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر (و) يجب (في الضلع) إذا جبر كما كان بعير (و) يجب في (كل واحدة من الترقوتين بعير) لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة (و) يجب (في كسر الذراع) وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد (و) في (الفخذو) في (الساق) والزند (إذا جبر ذلك مستقيما بعيران) لما روى

سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ولم يظهر له مخالف من الصحابه (وما عدا ذلك) المذكور (من الجراح وكسر العظام) نكرزة صلب وعصعص وعانة (ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لاجناية به ثم يقوم وهي أي الجناية (به قد برئت فما نقص من القيمة فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من الدية كأن) أي لو قدرنا أن (قيمته) أي قيمة المجني عليه لو كان (عبدا سليما) من الجناية (ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه) أي في جرحه (سدس ديته) لنقصه بالجناية سدس قيمته (إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر) من الشرع (فلا يبلغ بها) أي الحكومة (المقدر) كشجة دون الموضحة لاتبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها

باب العاقلة وما تحمله

+ العاقلة (عاقلة الإنسان) ذكور (عصابته كلهم من النسب والولاء قريبتهم) كالإخوة (وبعيدهم) كابن ابن ابن عم جد الجاني (حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه) وهم آباء الجاني و إن علوا وأبناؤه وإن نزلوا سواء كان الجاني رجلا أو امراة لحديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وإن العقل على عصبتها متفق عليه يقال عقلت من فلان إذا غرمت عنه دية جنايته ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء (ولا عقل على رقيق) لأنه لايملك ولو

ملك فملكة ضعيف (و) لاعلى (غير مكلف) كصغير ومجنون لأنهما ليسا من أهل النصرة (و) لاعلى (فقير) لايملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو معتملا لأنه ليس من أهل المواساة (ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني) لفوات المعاضدة والمناصرة ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال ومن لاعاقلة له أو له وعجزت فإن كان كافرا فالواجب عليه وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقطت (ولا تحمل العاقلة عمدا محضا) ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله (ولا) تحمل العاقلة أيضا (عبدا) أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه ولا تحمل أيضا جنايته (ولا) تحمل أيضا (صلحا) عن إنكار (ولا اعترافا لم تصدقه به) بأن يقر على نفسه

بجناية وتنكر العاقلة روى ابن عباس مرفوعا لاتحمل العاقله عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي عنه موقوفا (ولا) تحمل العاقلة أيضا (ما دون ثلث الدية التامة) أي ذكر حر مسلم لقضاء عمر أنها لاتحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لاقبلها ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب 0 %

1 فصل في كفارة القتل

+ (من قتل نفسا محرمة) ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو أجنبيا أو شارك في قتلها (خطأ) أو شبه عمد (مباشرة أو تسببا) كحفره بئرا (فعليه) أي على

القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا (الكفارة) عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه ويتعدد بتعدد قتل

باب القسامة $ + (وهي) لغة اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة وشرعا (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح و (من شروطها) أي القسامة (اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر) وكما بين البغاة وأهل العدل وسواء وجد مع اللوث أثر القتل أو لا (فمن ادعى عليه القتل من غير

لوث حلف يمينا واحدة وبرئ) حيث لابينة للمدعي كسائر الدعاوي فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل وإمكان القتل منه ووصف القتل في الدعوى وطلب جميع الورثه واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل وكون فيهم ذكور مكلفون وكون الدعوى على واحد معين ويقاد فيها إذا تمت الشروط (ويبدأ

بأيمان الرجال من ورثه الدم فيحلفون خمسين يمينا) وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر ويقضى لهم ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وسيد قن وقت حلف ومتى حلف الذكور فألحق حتى في عمد لجميع الورثة (فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينا أو عن بعضها (أو كانوا) أي الورثة كلهم (نساء حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ) إن رضي الورثة وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف

23 كتاب الحدود

+ جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله محارمه واصطلاحا عقوبة

مقدارة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها شروط الحد (لايجب الحد إلا على بالغ عاقل) لحديث رفع القلم عن ثلاثة (ملتزم) أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي لاحد إلا على من علمه (فيقيمه الإمام أو نائبه) مطلقا سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ويقيمه (في غير مسجد) ويحرم فيه لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود وتحريم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له هيئة الحد (ويضرب الرجل في الحد قائما) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (بسوط) وسط (لاجديد ولا خلق)

بفتح الخاء لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه (ولا يمد ولا يربط ولا يجرد) المحدود من ثيابه عند جلده لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (بل يكون عليه قميص أو قميصان) وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت (ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه (و) سن أن (يفرق الضرب على بدنه) ليأخذ كل عضو منه حظه ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه (ويتقي) وجوبا (الرأس والوجه والفرج والمقاتل) كالفؤاد والخصيتين لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته (والمرأة كالرجل فيه) أي فيما ذكر (إلا أنها تضرب جالسة) لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما (وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف) لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها وتعتبر لإقامته نية لا موالاة (وأشد

الجلد) في الحدود (جلد الزنا ثم) جلد (القذف ثم) جلد (الشرب ثم) جلد (التعزير) لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله ولا لحر أو برد ونحوه فإن خيف من السوط لم يتعين فيقام بطرف ثوب ونحوه ويؤخر لسكر حتى

يصحو (ومن مات في حد فهدر) ولاشيء على من حده لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن زاد ولو جلدة أو في السوط بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته (ولا يحفر للمرجوم في الزنا) رجلا كان أو امرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم

باب حد الزنا

+ وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (إذا زنا) المكلف (المحصن رجم حتى يموت) لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا يجلد قبله ولا ينفى (والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية) أو المستأمنة (في نكاح

صحيح) في قبلها (وهما) أي الزوجان (بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منهما) أي من هذه الشروط المذكورة (في أحداهما) أي أحد الزوجين (فلا إحصان لواحد منهما) ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه لابولد منها مع إنكار وطئه (وإذا زنا) المكلف (الحر غير المحصن جلد مائة جلدة) لقوله تعالى ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ وغرب أيضا مع الجلد (عاما) لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب (ولو) كان المجلود (امرأة) فتغرب مع محرم وعليها أجرته فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر ويغرب غريب إلى غير وطنه (و) إذا زنى (الرقيق) جلد (خمسين جلدة) لقوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير (ولا يغرب) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده ويجلد ويغرب مبعض بحسابه (وحد لوطي) فاعلا كان

أو مفعولا به (كزان) فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما ومملوكه كغيره ودبر أجنبية كلواط (ولا يجب الحد) للزنا (إلا بثلاثة شروط) (أحدها تغييب حشفة أصليه كلها) أو قدرها لعدم (في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي) فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائدة أو ميت أو في بهيمة بل يعزر وتقتل البهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور (حراما محضا) أي

خاليا من الشبهة وهو معنى قوله الشرط (الثاني انتفاء الشبهة) لقوله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك) أو محرمة برضاع ونحوه (أو لولده) فيها شرك (أو وطئ امرأة) في منزله (ظنها زوجته أو) ظنها (سريته) فلا حد (أو) وطئ امراة (في نكاح باطل اعتقد صحته أو) وطئ امرأة في (نكاح) مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه (أو) وطئ أمته في (ملك مختلف فيه) بعد قبضه كشركاء فضولي ولو قبل الإجازة (ونحوه) أي نحو ماذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة (أو أكرهت المرأة) المزني بها (على الزنا) فلا حد وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيها الشرط (الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت) الزنا (إلا بأحد أمرين) أحدهما أن يقر به) أي بالزنا مكلف ولو قنا (أربع مرات) لحديث ماعز وسواء كانت الأربع (في مجلس أو مجالس و) يعتبر أن (يصرح) بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد وذلك شبهة تدرأ الحد (و) يعتبر أن (لاينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد) فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم الأمر (الثاني) مما يثبت به الزنا (أن يشهد

عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفوفه) فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشأ في البئر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز قال له أنكتها لا تكني قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر قال نعم وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى (أربعة) فاعل يشهد لقوله تعالى ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ ويعتبر أن يكونوا (ممن تقبل شهادتهم فيه) أي في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية (سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين) فإن شهدوا في مجلسين فأكثر أو لم يكمل بعضهم الشهادة أو قام به مانع حدوا للقذف كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك) الحمل ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد لأن الحد يدرأ بالشبهة

باب حد القذف

وهو الرمي بزنا أو لواط (إذا قذف المكلف) المختار ولو أخرس بإشارة (محصنا) ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء (جلد) قاذف (ثمانين جلدة إن كان) القاذف (حرا) لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾) (وإن) كان القاذف (عبدا) أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد (أربعين) جلدة كما تقدم في الزنا (و) القاذف (المعتق بعضه) يجلد (بحسابه) فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة (وقذف غير المحصن) ولو قنه (يوجب التعزير) على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين (وهو) أي حد القذف (حق للمقذوف) فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي لكن لايستوفيه بنفسه وتقدم (والمحصن هنا) أي في باب القذف هو (الحر المسلم العاقل العفيف) عن

الزنا ظاهرا ولو تائبا منه (الملتزم الذي يجامع مثله) وهو ابن عشر وبنت تسع (ولا يشترط بلوغه) لكن لايحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته ومن قال لابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد (وصريح القذف) قوله (يا زاني يا لوطي ونحوه) كيا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ويا منيوك ويا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد (وكنايته) أي كناية القذف (ياقحبة) و (يافاجرة) و (ياخبيثة) و (فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه) كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه ولعربي يا نبطي ونحوه وزنت يدك أو رجلك ونحوه و (إن فسره بغير القذف قبل) وعزر كقوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه (وإن قذف أهل بلد أو) قذف (جماعة لايتصور منهم الزنا عادة عزر) لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه وكذا لو اختلفا في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد (ويسقط حد القذف بالعفو) أي عفو المقذوف

عن القاذف (ولا يستوفى) حد القذف (بدون الطلب) أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط وإلا فلجميع الورثة ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم

باب حد المسكر

+ أي الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان) لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه أحمد وأبو داود (ولا يباح شربه) أي شرب مايسكر كثيره (للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره) أي غير الخمر وخاف تلفا لأنه مضطر ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس (وإذا شربه) أي المسكر (المسلم) أو شرب ماخلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينا لت به (مختارا لعالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع

الحرية) لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيده في الشام رواه الدارقطني وغيره فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه ويصدق في جهل ذلك (و) عليه (أربعون مع الرق) عبدا كان أو أمة ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها لا من جهل التحريم لكن لايقبل ممن نشأ بين المسلمين ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين ويحرم عصير غلا وأتى عليه ثلاثة أيام بلياليها ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليله ما لم يشتد أو تتم له ثلاثة أيام

4 باب التعزير

(وهو) لغة المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة لأنه يمنع المعادي من الإيذاء واصطلاحا (التأديب) لأنه يمنع مما لايجوز فعله (وهو) أي التعزير (واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه) أي كمباشرة دون فرج (و) ك (سرقة لا قطع فيها) لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز (و) ك (جناية لاقود فيها) كصفع ووكز (و) ك (إتيان المرأة المرأة والقذف

بغير الزنا) إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف فإن كان فلا حد ولا تعزير (ونحوه) أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك أو خصمك ولا يحتاج في إقامه التعزير إلى مطالبة (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعا لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط

إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وللحاكم نقصه عن العشرة حسب مايراه لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا لفعل علي رضي الله تعالى عنه ومن وطىء أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم

فيهما ومن وطىء أمة له فيها شرك عزر بمائة إلا سوطا ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه (ومن استمنى بيده) من رجل أو أمرأة (بغير حاجة عزر) لأنه معصية وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة

باب القطع في السرقة

+ وهي أخذ مال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه (إذا أخذ) المكلف (الملتزم) مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه (نصابا من حرز مثله من مال معصوم) بخلاف حربي (لا شبهة له فيه على وجه الإختفاء قطع) لقوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ ولحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا (فلا قطع على منتهب) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة (ولا مختلس) وهو الذي يخطف الشيء ويمر به (ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها) لأن ذلك ليس بسرقة ولكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إن بلغت نصابا لقول ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال أحمد لاأعرف شيئا يدفعه (ويقطع الطرار) وهو (الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه) أو بعد سقوطه إن بلغ نصابا لأنه سرقه من حرز (ويشترط) للقطع في السرقة ستة شروط أحدها (أن يكون المسروق مالا محترما) لأن ما ليس بمال لا حرمة له ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال

(فلا قطع بسرقة آلة لهو) لعدم الاحترام (ولا) بسرقة (محرم كالخمر) وصليب وآنية فيها خمر ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحر ولو صغيرا ولا بما عليهما الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله (ويشترط) أيضا (أن يكون) المسروق (نصابا) وهو أي نصاب السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة أو تخلص من مغشوشة (أو ربع دينار) أي مثقال وإن لم يضرب (أو عرض قيمته كأحدهما) أي ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وغيرهما وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر دراهما رواه أحمد (وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه لم يسقط القطع لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها (أو ملكها) أي العين المسروقة (السارق) ببيع أو هبة أو غيرهما (لم يسقط القطع) بعد الترافع إلى الحاكم

(وتعتبر قيمتها) أي قيمة العين المسروقة (وقت إخراجها من الحرز) لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع (فلو ذبح فيه) أي في الحرز (كبشا) فنقصت قيمته (أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب) السرقة (ثم أخرجه) من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا (أو أتلف فيه) أي في الحرز (المال لم يقطع) لأنه لم يخرج منه شيئا (و) الشرط الثالث (أن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز) كما لو وجد بابا مفتوحا

أو حرزا مهتوكا (فلا قطع) عليه (وحرز المال ماالعادة حفظه فيه) إذ الحرز معناه الحفظ ومنه احترز أي تحفظ (ويختلف) الحرز (باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه) لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات (فحرز الأموال) أي النقود (والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران) أي الأبنية الحصينه والمحال المسكونة من البلد (وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) والغلق اسم للقفل خشبا كان أو حديدا وصندوق بسوق وثم حارس حرز (وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما) كقدور طبيخ وخزف (وراء الشرائج) وهي مايعمل من قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره (إذا كان في السوق حارس) لجريان العادة بذلك (وحرز الحطب والخشب الحظائر) جمع حظيرة بالحاء المهملة والظاء المعجمة ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط (وحرز المواشي الصير) جمع صيرة وهي حظيرة الغنم (وحرزها) أي المواشي (في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا) فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز وحرز سفن في شط بربطها وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم وحمولتها بتقطيرها مع قائد يراها ومع عدم تقطير بسائق براها وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ كقعوده على متاع وإن فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل ضمن ولا قطع على سارق إذا وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه (و) الشرط الرابع (أن تنتفي

الشبهة) عن السارق لحديث ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (فلا يقطع) سارق (بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا) بسرقة (من مال ولده وإن سفل) لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر (والأب والأم في هذا سواء) لما ذكر (ويقطع الأخ) بسرقة مال أخيه (و) يقطع (كل قريب بسرقة مال قريبه) لأن القرابة هنا لاتمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر فلم تمنع القطع (ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه) روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد (وإذا سرق عبد) ولو مكاتبا (من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه) فلا قطع (أو) سرق (حر مسلم) أو قن (من بيت المال) فلا قطع (أو) سرق (من غنيمة لم تخمس) فلا قطع لأن لبيت المال فيها خمس الخمس (أو) سرق (فقير من غلة موقوفة على الفقراء) فلا قطع لدخوله فيهم (أو) سرق (شخص من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لايقطع بالسرقة منه) كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبه (لم يقطع) للشبهة الشرط الخامس ثبوت السرقة وقد ذكره بقوله (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين) يصفانها بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه (أو بإقرار) السارق (مرتين) بالسرقة يصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لاقطع فيها (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع) ولا بأس بتلقينه الإنكار (و) الشرط السادس (أن يطالب المسروق

منه) السارق (بماله) فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة (وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه (قطعت يده اليمنى) لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة (من مفصل الكف لقول) أبي بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة (وحسمت) وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع (ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا) بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال (أو غيرهما) من جمار أو غيره (أضعفت عليه القيمة) أي ضمنه يعوضه مرتين قاله القاضي واختاره الزركشي وقدم في التنقيح أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية وقطع به في المنتهى وغيره لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص (ولا قطع) لفوات شرطه وهو الحرز

باب حد قطاع الطريق

+ (وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح) ولو عصا أو حجرا (في الصحراء أو البنيان) أو البحر (فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة لا سرقة) ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة (فمن) أي أي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا (منهم) أي من قطاع الطريق (قتل مكافئا) له (أو غيره) أي غير مكافىء (كالولد) يقتله أبوه (و) ك (العبد) يقتله الحر (و) ك (الذمي) يقتله المسلم (وأخذ المال) الذي قتله لقصده (قتل) وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه (ثم صلب) قاتل من يقاد به في غير المحاربة (حتى يشتهر أمره)

ولا يقطع مع ذلك (وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب) لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي (وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف) كقطع يد أو رجل ونحوها (تحتم استيفاء) كالنفس صححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما وعنه لايتحتم استيفاؤه قال في الإنصاف وهو المذهب وقطع به في المنتهى وغيره (وإن أخذ كل واحد) من المحاربين (من المال قدر مايقطع بأخذه السارق) من مال لا شبهة له فيه (ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد) وجوبا (وحسمتا) بالزيت المغلي (ثم خلي) سبيله (فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا) متفرقين (فلا يتركوا يأوون إلى بلد) حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم رواه الشافعي ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم (ومن تاب منهم) أي المحاربين (قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان) واجبا (لله) تعالى (من نفي وقطع) يد ورجل (وصلب وتحتم قتل) لقوله تعالى ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ وأرجلهم من

خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ﴿ من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾

وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا إن يعفى له عنها من مستحقها ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل (ومن صال على نفسه أو حرمته) كأمه وبنته وأخته وزوجته (أو مال آدمي أو بهيمة فله) أي للمصول عليه (الدفع عن ذلك بأسهل مايغلب على ظنه دفعه به) فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه (فإن لم يندفع) الصائل (إلا بالقتل فله) أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائل (ولا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره (وإن قتل) المصول عليه (فهو شهيد) لقوله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال (ويلزمه الدفع عن نفسه) في غير فتنة لقوله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره (و) عن (حرمته)

وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس (دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك فإن فعل فلا ضمان عليه (ومن دخل منزله رجل متلصصا فحكمه كذلك) أي يدفعه بالأسهل فإن أمره بالخروج فخرج كذلك لم يضربه وإلا فله ضربه بأسهل ماينـدفع به فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف

عينه أو نحوها فتلفت فهدر بخلاف مستمع قبل إنذاره

باب قتال أهل البغي

+ أي الجور والظلم والعدول عن الحق (إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة) بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم (على الإمام بتأويل سائغ) ولو لم يكن فيهم مطاع (فهم بغاة) ظلمة فإن كانوا جمعا يسيرا لاشوكة لهم أو لم يخرجوا بتأويل أو خرجوا بتأويل غير

سائغ فقطاع طريق ونصب الإمام فرض كفاية ويجبر من تعين لذلك وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما (و) يجب (عليه) أي على الإمام (أن يراسلهم) أي البغاة (فيسألهم) عن (ماينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها) لقوله تعالى ﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ والإصلاح إنما يكون بذلك فإن كان ماينقمون منه مما لايحل أزاله وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه (فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم (وإلا) يرجعوا (قاتلهم) وجوبا وعلى رعيته معونته ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمنجنيق ونار إلا لضرورة وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن

ترك القتال ولا قود بقتلهم بل الدية ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب فإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غير أخذه وما تلف حال حرب غير مضمون وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو) طلب (رياسة فهما ظالمتان وتضمن

كل واحدة) من الطائفتين (ما أتلفت) على (الآخرى) قال الشيخ تقي الدين فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله وما جهل متلف ضمنتاه على السواء

باب حكم المرتد

+ (وهو) لغة الراجع قال تعالى ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم ﴾ واصطلاحا (الذي يكفر بعد إسلامه) طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل (فمن أشرك بالله) تعالى كفر لقوله تعالى ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ أو جحد ربوبيته سبحانه (أو) جحد (وحدانيته أو) جحد (صفه من صفاته) كالحياة والعلم كفر (أو اتخذ لله) تعالى (صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو) جحد بعض (رسله

أو سب الله) سبحانه (أو) سب (رسوله) أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة (فقد كفر) لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده (ومن جحد تحريم الزنا أو) جحد (شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها) أي على تحريمها أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه أو جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا (بجهل) أي بسبب جهله وكان ممن يجهل مثله ذلك (عرف) حكم (ذلك) ليرجع عنه (وإن) أصر و (كان مثله لا يجهله كفر) لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وكذا لو سجد لكوكب ونحوه أو أتى بقول أو فعل صريح

في الاستهزاء في الدين أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده %

1 فصل

+ (ومن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه) أي إلى الإسلام (ثلاثة أيام) وجوبا (وضيق عليه) وحبس لقول عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك في الموطأ ولو لم تجب الإستتابة لما برىء من فعلهم (فإن) أسلم لم يعزر وإن (لم يسلم قتل بالسيف) ولا يحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولاتعذبوه بعذاب الله يعني النار أخرجه البخاري وأبو داود إلا رسول كفار فلا يقتل ولا يقتله إلا إمام أو نائبه مالم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله وأخذ ما معه (ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى (أو) سب (رسوله) سبا صريحا أو تنقصه (ولا) توبة (من تكررت ردته) ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي

يظهر الإسلام ويخفي الكفر (بل يقتل بكل حال) لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام ويصح إسلام مميز يعقله وردته

لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثه أيام (وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه بأن يشهد) المرتد أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى أتى عل صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آووا أخاكم رواه أحمد (ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه) كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب (فتوبته مع) إتيانه ب (الشهادتين إقراره بالمجحود به) من ذلك لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده (أو قوله أنا) مسلم أو (بريء من كل دين يخالف الإسلام) ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويمنع المرتد من التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا ويكفر ساحر بركب المكنسة فتسير به في الهواء

ونحوه لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر ويكف عنه ويحرم

طلسم ورقية بغير العربي ويجوز الحل بسحر ضرورة

24

ج ٣ - ص ٣٤٥

كتاب الأطعمة

+ جمع طعام وهو مايؤكل ويشرب (والأصل فيها الحل) لقوله تعالى ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ فيباح كل طعام (طاهر) بخلاف متنجس ونجس (لا مضرة فيه) احترازا عن السم ونحوه حتى المسك ونحوه كالعنبر (من حب وثمر ونحوهما) من الطاهرات (ولا يحل نجس كالميتة والدم) لقوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ الآية (ولا) يحل (مافيه مضرة كالسم ونحوه) لقوله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه (و) إلا (ما له ناب

يفترس به) أي ينهش بنابه لقول أبي ثعلبه الخشني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه (غير الضبع) لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع احتج به أحمد والذي له ناب (كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور) مطلقا (والنمس والقرد والدب) والفنك والثعلب والسنجاب والسمور (و) إلا (ماله مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة (والبومة) لقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور رواه أبو داود (و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير (كالنسر والرخم واللقلق والعقعق) وهو القاق (والغراب الأبقع والخطاف وهو) طائر (أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير و) إلا (مايستخبثه) العرب ذوو اليسار

(كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط و) إلا (ماتولد من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل والحمر الأهلية (والسمع) وهو ابن الذئب والضبع وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا %

1 فصل

+ (وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنه حرام (فحلال) على الأصل (كالخيل) لما سبق من حديث جابر (وبهيمة الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ والدجاج والوحشي من الحمر و من (البقر) كالإيل والتيتل والوعل والمها (والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش) كالزرافة والوبر واليربوع وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزرع لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى ﴿ ويحل لهم الطيبات ﴾

ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ إلا الضفدع لأنها مستخبثة (و) إلا (التمساح) لأنه ذو ناب يفترس به (و) إلا (الحية) لأنها من المستخبثات وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن وقلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم إن لم ينضج بطبخ لا لحم منتن أو نيء (ومن اضطر إلى محرم) بأن خاف التلف

إن لم يأكله (غير السم حل له) إن لم يكن في سفر محرم (منه ما يسد رمقه) أي يمسك قوته وحفظها لقوله تعالى ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾

وله التزود إن خاف ويجب تقديم السؤال على أكله ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة فإن لم يجد إلا طعام غيره فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل مايسد رمقه فقط بقيمته فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل ويعطيه عوضه (ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) كثياب (لدفع برد أو) حبل أو دلو (لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له) أي لمن اضطر إليه (مجانا) مع عدم حاجته إليه لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ وإن لم يجد

المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله ولا أكل عضو من أعضاء نفسه (ومن مر بثمر بستان في شجره أو ساقط عنه ولا حائط عليه) أي على البستان (ولا ناظر) أي حافظ له فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم وليس له صعود شجرة ولا رمية بشيء ولا الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية

(ويجب) على المسلم (ضيافة المسلم المجتاز به في القرى) دون الأمصار (يوما وليلة) قدر كفايته مع آدم لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته متفق عليه ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره

باب الذكاة

+ يقال ذكى الشاة ونحوها تذكية أي ذبحها فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة) لأن غير المذكى ميتة وقال تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ إلا الجراد والسمك وكل ما لا أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وغيره وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا بالذكاة وحرم بلع السمك حيا وكره شيه حيا لا جراد لأنه لا دم له (ويشترط للذكاة أربعة شروط أحدها (أهلية المذكي بأن يكون عاقلا) فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية (مسلما) كان (أو كتابيا) أبواه كتابيان لقوله تعالى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ يعيش إلا في الماء) فيحل بدون

ذكاة لحل ميتته لحديث ابن عمر يرفعه قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم (ولو) كان المذكي مميزا أو (مراهقا أو امرأة أو أقلف) لم يختن ولو بلا عذر (أو أعمى) أو (وثني ومجوسي ومرتد) لمفهوم قوله تعالى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴾ حائضا أو جنبا (ولا تباح ذكاة سكران ومجنون) لما تقدم

(و) لا ذكاة حل لكم الشرط (الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد) ينهر الدم بحده (ولو) كان (مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره) نكشب له حد وذهب وفضة وعظم (إلا السن والظفر) لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه الشرط (الثالث قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (و) قطع (المريء) بالمد وهو مجرى الطعام والشراب ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ولا يضر رفع يد الذابح إن

أتم الذكاة على الفور والسنة نحر الإبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها (فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة و) النعم (الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه) روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم (إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (فلا يباح) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب جانب الحظر وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا ولو أبان رأسه حل مطلقا والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت

والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل وما قطع حلقومه أو ما أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها والشرط (الرابع أن يقول) الذابح (عند) حركة يده (بالذبح بسم الله) لقوله تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ ولا يجزيه غيرها كقوله باسم الخالق ونحوه لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها (فإن تركها) أي التسمية (سهوا أبيحت) الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمده رواه سعيد (لا) إن ترك التسمية (عمدا) ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه أعاد التسمية ويسن مع التسمية التكبير لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح ويكره أن يذبح بآلة كالة) لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) رواه الشافعي

وغيره (و) يكره أيضا (أن يحدها والحيوان يبصره) لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وغيره (و) يكره أيضا (أن يوجهه) أي الحيوان (إلى غير القبلة) لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقة الأيسر والرفق به والحمل على الآلة بقوة (و) يكره أيضا (أن يكسر عنقه) أي عنق ما ذبح (أو بسلخه قبل أن يبرد) أي قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لاتعجلوا الأنفس قبل أن تزهق رواه الدارقطني وإن ذبح كتابي مايحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح

باب الصيد

هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد و (لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط) (أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة) فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه وكذا ماشارك فيه الشرط الثاني (الآلة وهي نوعان) أحدهما (محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) الصيد (فإن قتله بثقله لم يبح) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل (وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لايحل ما قتل به) ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل (والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته) الجارحة (إن

كانت معلمة) سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب لقوله تعالى ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ﴾

إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا) للصيد (فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح) ما صاده (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل) الصيد لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل الشرط (الرابع التسمية عند إرسال السهم أو) إرسال (الجارحة فإن تركها) أي التسمية (عمدا أو سهوا لم يبح) الصيد لمفهوم قوله صلى الله عليه سلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل لا على سهم ألقاه ورمى بغيره بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاه وذبح بغيرها (ويسن أن يقول معها) أي مع بسم الله (الله أكبر كما في الذكاة) لأنه صلى الله عليه وسلم

كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر وكان ابن عمر يقوله ويكره الصيد لهوا وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب

25

كتاب الأيمان

+ جمع يمين وهو الحلف والقسم و (اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث) فيها (هي اليمين) التي يحلف فيها (ب) اسم (الله) الذي لا يسمى به غيره كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن أو الذي يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والخالق والرازق والمولى (أو) ب (صفة من صفاته) تعالى كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته (أو بالقرآن أو بالمصحف) أو بسورة أو آية منه ولعمر الله يمين وما لا يعد

من أسمائه تعالى كالشيء والموجود وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا (والحلف بغير الله) سبحانه وصفاته (محرم) لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه ويكره الحلف بالأمانه (ولا تجب به) أي بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث (ويشترط لوجوب الكفارة) إذا حلف بالله تعالى (ثلاثة شروط) (الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي) اليمين (التي قصد عقدها على) أمر (مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي) اليمين (الغموس) لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار (ولغو اليمين) هو (الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله) في أثناء كلامه (لا والله وبلى والله) لحديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته

لا والله وبلى والله رواه أبو داود وروي موقوفا (وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع) لقوله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ وهذا منه ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم الشرط (الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط (الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه) كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه مختارا (أو بترك ما حلف على فعله) كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه (مختارا ذاكرا) ليمينه (إذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة) لأنه لا إثم عليه (ومن قال في يمين مكفرة) أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار (إن شاء الله لم يحنث) في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه لفظا أو حكما لقوله عليه

الصلاة و السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد وغيره (ويسن الحنث في اليمين إذا كان) الحنث (خيرا) كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه ويخير في مباح وحفظها فيه أولى ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل ويسن (ومن حرم حلالا سوى زوجته) لأن تحريمها ظهار كما تقدم سواء كان الذي حرمه (من أمة أو طعام أو لباس أو غيره) كقوله ماأحل الله علي حرام ولا زوجة له أو قال طعامي علي كالميتة (لم تحرم)

عليه لأن الله سماه يمينا بقوله ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ إلى قوله ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ واليمين على الشيء لا تحرمه (وتلزمه كفارة يمين إن فعله) لقوله تعالى ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ أي التكفير وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه %

1 فصل في كفارة اليمين

+ (يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين للرجل ثوب يجزيه في صلاته وللمرأة درع وخمار كذلك (أو عتق رقبة فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (فصيام ثلاثة أيام) لقوله تعالى ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ﴾ / < متتابعة > / وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام

متتابعة وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله (ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد) ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطيت والله لاأخذت (فعليه كفارة واحدة) لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس (وإن اختلف موجبها) أي موجب الأيمان وهو الكفارة (كظهار ويمين بالله) تعالى (لزماه) أي الكفارتان (ولم يتداخلا) لعدم اتحاد الجنس ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه ويكفر كافر بغير صوم

باب جامع الأيمان المحلوف بها

+ (يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء مانوى فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش والبساط الأرض قدمت على عموم لفظه ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم (فإن عدمت النية رجع إلى سبب

اليمين وما هيجها) لدلالة ذلك على النية فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاء قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا وكذا ليأكلن شيئا أو ليفعلنه غدا وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا أن باعه بأقل منها وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل مافيه منة (فإن عدم ذلك) أي النية وسبب اليمين الذي هيجها (رجع إلى التعيين) لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام بالكلية (فإذا حلف لاألبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه) حنث (أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا) وكلمه حنث (أو) حلف لا كلمت (زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا) هذا (أو مملوكه سعيدا) هذا (فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم) حنث (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا) وأكله حنث (أو) حلف لاأكلت (الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا) وأكله حنث (أو) حلف لاأكلت (هذا اللبن فصار اللبن جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل) لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لالبست هذا الغزل فصار ثوبا وكذا حلفه لايدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه (إلا أن ينوي) الحال أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم 0

فصل

(فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعين (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم وهو) أي الاسم (ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي) وقد لايختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها (فالشرعي) من الأسماء (ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة) كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة فالاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك (ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح (فإذا حلف لايبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا يبيع الخمر أو

الخنزير حنث بصورة العقدة) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح وكذا إن قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق طلقت بصورة طلاق الأجنبية (و) الاسم (الحقيقي) هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم (فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه) ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان (لم يحنث) لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم (ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه) كالجبن واللبن (وكل ما يصبغ به) عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم لأن هذا معنى التأدم (و) إن حلف (لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا) أو عمامة أو قلنسوة (أو نعلا حنت) لأنه ليس ملبوس حقيقة وعرفا (وإن حلف لايكلم إنسانا حنت بكلام) كل (إنسان) لأنه نكرة في سياق النفي فيعم حتى (ولو قال له تنح أو اسكت أولا كلمت زيدا) فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينو مشافهته (و) إن حلف (لايفعل شيئا فوكل من فعله حنث) لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه قال تعالى (محلقين رؤوسكم) وإنما الحالق غيرهم (إلا أن ينوي مباشرته بنفسه) فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله (و) الاسم (العرفي اشتهر مجازه فغلب) على الحقيقة (كالرواية) في العرف للمزادة وفي الحقيقة للجمل الذي يستقي عليه (والغائط) في

العرف للخارج المستقذر وفي الحقيقة لفناء الدار وما اطمأن من الأرض (ونحوهما) كالظعينة والدابة والعذرة (فتتعلق اليمين بالعرف) دون الحقيقة لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس (فإن حلف على وطء زوجته أو) حلف على (وطء دار تعلقت يمينه بجماعها) أي جماع من حلف على وطئها لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف (و) تعلقت يمينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطأها لما ذكر (وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لاآكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه) لم يحنث (أو) حلف (لايأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث) لأن ما أكله لايسمى سمنا ولا بيضا (وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه) فيما أكله (حنث) لأكله المحلوف عليه %

2 فصل

+ (وإن حلف لايفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث) لأن فعل المكره غير منسوب إليه (وإن حلف على نفسه أو غيره ممن) يمتنع بيمينه و (يقصد منعه كالزوجة والولد أن

لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق أوالعتاق) بفتح العين (فقط) أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار لأن الطلاق والعتاق حتى آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه فإنها حق الله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان (و) إن حلف (على من لايمتنع بيمينه من سلطان أو غيره) كأجنبي لايفعل شيئا (ففعله حنث) الحالف (مطلقا) أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا (وإن فعل هو) أي الحالف لايفعل شيئا أو من لايمتنع بيمينه من سلطان أو أجنبي (أو غيره) أي ما ذكر (ممن قصد منعه) كزوجة وولد (بعض ما حلف على كله) كما لو حلف لايأكل هذا الرغيف فأكل بعضه (لم يحنث) لعدم وجود المحلوف عليه (ما لم تكن له نية) أو قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث

2 باب النذر $ + النذر لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه

و (لايصح) النذر (إلا من بالغ عاقل) مختار لحديث رفع القلم عن ثلاث (ولو) كان (كافرا) نذر عبادة لحديث عمر إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك (والصحيح منه) أي من المنذر (خمسة أقسام) أحدها النذر (المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين) لما روى عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب 0 (الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من الشرط المعلق عليه (أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب) كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه (فيخير بين فعله وبين كفارة يمين) لحديث عمران بن حصين قال سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه (الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته) فإن نذر ذلك (فحكمه ك) القسم (الثاني) يخير بين فعله وكفارة يمين (وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له (أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى من فعله وإن فعله فلا كفارة (الرابع نذر المعصية

ك) نذر (شرب الخمر و) نذر (صوم يوم الحيض و) يوم (النحر) وأيام التشريق (فلا يجوز الوفاء به (لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (ويكفر) إن لم يفعله روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض (الخامس نذر التبرر مطلقا) أي غير معلق (أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه) كالعمرة والصدقة وعيادة المريض فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي ومثال المعلق (كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه (فوجد الشرط لزمه الوفاء به) أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري (إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) من يسن له فيجزيه قدر ثلثه ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة لما نذر أن يخلع من ماله صدقة لله تعالى ويجزي

عنك الثلث رواه أحمد (أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي من ماله كألف (يزيد) ماسماه (على ثلث الكل فإنه يجزيه) أن يتصدق ب (قدر الثلث) ولا كفارة عليه جزم به في الوجيز وغيره والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره (وفيما عداها) أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه (يلزمه) الصدقة ب (المسمى) لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه (ومن نذر صوم شهر) معين كرجب أو مطلق (لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع سواء صام شهرا بالهلال أو ثلاثين يوما بالعدد (وإن نذر أياما معدودة) كعشرة أيام أو ثلاثين يوما (لم يلزمه التتابع) لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع (إلا بشرط) بأن يقول متتابعة (أو نية) التتابع ومن نذر صوم الدهر لزمه فإن أفطر

كفر فقط بغير صوم ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي ويقضي فطره برمضان ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار ونحوه ومن نذر

صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر وإن نذر صوما وأطلق أو صوم يوم لزمه يوم بنية من الليل ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة

26

كتاب القضاء

+ القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه ومنه ﴿ فقضاهن سبع سماوات في يومين ﴾ واصطلاحا تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات (وهو فرض كفاية) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم) بكسر الهمزة (قاضيا) لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق (ويختار) لنصب القضاء (أفضل من يجده علما وورعا) لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم (ويأمره بتقوى الله) لأن التقوى رأس الدين (و) يأمره (بأن يتحرى العدل) أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل (ويجتهد) القاضي (في إقامته) أي إقامة العدل بين الأخصام ويجب

على من يصلح و لم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل (فيقول) المولي لمن يوليه (وليتك الحكم أو قلدتك) الحكم (ونحوه) كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك أو استخلفتك في الحكم والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم (وبكتابة) بالولاية (في البعد) أي إذا كان غائبا فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليها (وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض) أي أخذه لربه ممن هو عليه (والنظر في أموال غير الراشدين) كالصغير والمجنون والسفيه وكذا مال غائب (والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها

وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها) من النساء (وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والعيد) ما لم يخصها بإمام (والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه) كجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل بمن يثبت جرحه والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع (ويجوز أن يولي) القاضي (عموم النظر في عموم العمل) بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان ويجوز أن (يوليه خاصا فيهما) بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا (أو) يوليه خاصا (في أحدهما) بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان وإذا ولاه ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطاريء إليه فقط وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين

لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه (ويشترط في القاضي عشر صفات) (كونه بالغا عاقلا) لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره (ذكرا) لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قو م ولوا أمرهم امرأة (حرا) لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده (مسلما) لأن الإسلام شرط للعدالة (عدلا) ولو تائبا من قذف فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ الآية (سميعا) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين (بصيرا) لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه (متكلما) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته (مجتهدا) إجماعا ذكره ابن حزم قاله في الفروع (ولو) كان مجتهدا (في

مذهبه) المقلد فيه لإمام من الأئمة فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد قال في الفروع وهو كما قال ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعا

أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك (وإذا حكم) بتشديد الكاف (اثنان) فأكثر بينهما (رجلا يصلح للقضاء) فحكم بينهما نفذ حكمه (في المال والحدود واللعان وغيرها) من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه لأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا

باب أدب القاضي

+ أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها (وينبغي) أي يسن (أن يكون قويا من غير عنف) لئلا يطمع فيه الظالم والعنف ضد الرفق (لينا من غير ضعف) لئلا يهابه صاحب الحق (حليما) لئلا يغضب من كلام الخصم (ذاأناة) أي تؤدة وتأن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي (و) ذا (فطنة) لئلا يخدعه بعض الأخصام ويسن أيضا أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب ولا يتطير وإن تفاءل فحسن (وليكن مجلسه في وسط البلد) إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه

وليكن مجلسه (فسيحا) لئلا يتأذى فيه بشيء ولا يكره القضاء في الجامع ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم (و) يجب أن (يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه) إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوى (وينبغي) أي يسن (أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب و) أن (يشاورهم فيما يشكل عليه) إن أمكن فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره لقوله تعالى ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لخبر أبي بكرة مرفوعا لا يقضين حاكم بين اثنين

وهو غضبان متفق عليه (أو) وهو (حاقن أو في شدة جوع أو) في شدة (عطش أو) في شدة (هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج) لأن ذلك كله يشغل الفكرالذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب فهو في معنى الغضب (وإن خالف) وحكم في حال من هذه الأحوال (فأصاب الحق نفذ) حكمه لموافقته الصواب (ويحرم) على الحاكم (قبول رشوة) لحديث ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال الترمذي حديث حسن صحيح (وكذا) يحرم على القاضي قبول (هدية) لقوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول رواه أحمد (إلا) إذا كانت الهدية (ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة) فله أخذها كمفت قال القاضي ويسن له التنزه عنها فإن

قدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة لأنها كالرشوة ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به (ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود) ليستوفي بهم الحق ويحرم تعيينه قوما بالقبول (ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له) كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو رعيته كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيم حبسوا فمن استحق الإبقاء أبقاه ومن استحق الإطلاق أطلقه ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني وجوبا ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحالة أقره ومن فسق عزله ولا ينقض من

حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله كقتل مسلم بكافر وجعل من وجد عين ماله عند من أفلس أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه والناقض له حاكمه إن كان (ومن

ادعى على غير برزة) أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها (لم تحضر) أي لم يأمر الحاكم بإحضارها (وأمرت بالتوكيل) للعذر فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت ولا يعتبر محرم تحضر معه (وإن لزمها) أي غير البرزة إذا وكلت (يمين أرسل) الحاكم

(من يحلفها) فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما (وكذا) لا يلزم إحضار (المريض) ويؤمر أن يوكل فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه ويقبل قول قاض معزول عدل لايتهم كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولو لم يذكر مستنده أو لم يكن بسجله

2 باب طريق الحكم وصفته

+ طريق كل شيء ما توصل به إليه والحكم فصل الخصومات (إذا

حضر إليه خصمان) يسن أن يجلسهما بين يديه و (قال أيكما المدعي) لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما (فإن سكت) القاضي (حتى يبدأ) بالبناء للمفعول أي حتى تكون البدأة بالكلام من جهتهما (جاز) له ذلك (فمن سبق بالدعوى قدمه) الحاكم على خصمه وإن ادعيا معا أقرع بينهما فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد ولا تسمع

دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوى لا بينة بحق معين قبل دعواه فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها وإن لم يسأله سؤاله (فإن أقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفى إلا بسؤاله (وإن انكر) بأن قال المدعي قرضا أو ثمنا فقال المدعى عليه ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق و (قال) الحاكم (للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت فإن أحضرها) أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها فإذا شهدت (سمعها) وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها (وحكم بها) أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي (ولا يحكم القاضي (بعلمه) ولو في غير حد لأن تجويز القضاء بعلم القاضي

يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي (وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه) لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه وهو حديث حسن صحيح قاله في شرح المنتهى وتكون يمينه (على صفة جوابه) للمدعي (فإن سأل) المدعي من القاضي (إحلافه أحلفه وخلى سبيله) بعد تحليفه إياه لأن الأصل براءته (ولا يعتد بيمينه) أي يمين المدعى عليه (قبل) أمر الحاكم له و (مسألة المدعي) تحليفه لأن الحق في اليمين للمدعي فلا

بستوفى إلا بطلبه (وإن نكل) المدعى عليه من اليمين (قضي عليه) بالنكول رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه (فيقول) القاضي للمدعى عليه (إن حلفت) خليت سبيلك (وإلا) تحلف (قضيت عليك) بالنكول (فإن لم يحلف قضي عليه) بالنكول (فإن حلف المنكر) 2 وخلى الحاكم سبيله (ثم إن أحضر المدعي بينة) عليه (حكم) القاضي (بها لم تكن اليمين مزيلة للحق) هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها %

1 فصل في صحة الدعوى

+ (ولا تصح الدعوى إلا محررة) لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع ولا تصح أيضا إلا (معلومة

المدعى به) أي تكون بشيء معلوم ليأتي الإلزام (إلا) الدعوى ب (ما تصححه مجهولا كالوصية) بشيء من ماله (و) الدعوى ب (عبد من عبيده) جعله (مهرا ونحوه) كعوض خلع أو أقربه فيطالبه بما وجب له ويعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالب به ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستيلاد وكتابة

ولا بد أن تنفك عما يكذبها فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق (وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه) لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد (وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (وإن ادعى) إنسان (الإرث ذكر سببه) لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه ويعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس وإحضار عين بالبلد ليتعين وإن كانت غائبة وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا (وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا) لقوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم (ومن جهلت عدالته سأل) القاضي (عنه) ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما وتقدم بينة جرح على تعديل وتعديل الخصم وحده أي تصديقه للشاهد تعديل له (وإن علم) القاضي) (عدالته) أي عدالة الشاهد (عمل بها) ولم يحتج إلى التزكية وكذا لو علم فسقه (وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به) أي

بالجرح ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة (وانظر) من ادعى الجرح (له ثلاثة إن طلبه وللمدعي ملازمته) أي ملازمة خصمه في مدة الانتظار لئلا يهرب (فإن لم يأت) مدعي الجرح (ببينة حكم عليه) لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه (وإن جهل) القاضي (حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم) لتثبت عدالتهم فيحكم له (ويكفي فيها) أي في التزكية (عدلان بشهدان بعدالته) أي بعدالة الشاهد (ولا تقبل في الترجمة وفي التزكية و) في (الجرح والتعريف) عند حاكم (والرسالة) إلى قاض آخر بكتابه ونحوه (إلا قول عدلين) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله (وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينه

فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها فيه صرفه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به (ويحكم على الغائب) مسافة القصر (إذا ثبت عليه الحق) لحديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر

وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته (وإن ادعى) إنسان (على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم) أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر (وأتى) المدعي (ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة) عليه حتى يحضر مجلس الحكم لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله

باب كتاب القاضي إلى القاضي

+ أجمعت الأمة على قبوله أي كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه (فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق) لآدمي كالقرض والبيع والإجارة (حتى القذف) والطلاق والقود والنكاح والنسب لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات و (لا) يقبل (في حدود الله) تعالى (كحد الزنا ونحوه) كشرب الخمر لأن حقوق الله تعالى مبينة على الستر والدرء بالشبهات (ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه (وإن كان)

كل منهما (في بلد واحد) لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال (ولا يقبل) كتابه (فيما ثبت عنده ليحكم) المكتوب إليه (به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر) فأكثر لأنه نقل شهادته إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة (ويجوز أن يكتب) كتابه (إلى قاض معين و) أن يكتبه (إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين) من غير تعيين ويلزم من وصل إليه قبوله لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله كما لو كتب إلى معين (ولا يقبل) كتاب القاضي (إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين) عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم (فيقرأه) القاضي الكاتب (عليهما) أي على الشاهدين (ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان) أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين (ثم يدفعه إليهما) أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما ولا يشترط وإن اشهدهما عليه مدرجا مختوما لم يصح

باب القسمة

من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما والقسم بكسر القاف النصيب وهي نوعان قسمة تراض وأشار إليها بقوله (لاتجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (أو) لا تنقسم إلا ب (رد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضى الشركاء) كلهم لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره وذلك (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين) والشجر المفرد (والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي بعض الأرض (فهذه القسمة في حكم البيع) تجوز بتراضيهما ويجوز فيها مايجوز في البيع خاصة (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) لأنها معاوضة ولما فيها من الضرر ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر فإن

أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة ومن بينها دار لها علو وسفل وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع

ج ٣ - ص ٤٠٧

النوع الثاني قسمة إجبار وقد ذكرها بقوله (وأما ما لا ضرر) في

قسمته (ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض) الواسعة (والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر) شريكه (الآخر عليها) إن امتنع من القسمة مع شريكه ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع أجبر ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا (وهذه القسمة) وهي قسمة الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر (لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا وما

يكال وزنا وعكسه وموقوف ولو على جهة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت (ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم و) أن يتقاسموا (بقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه) وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها ويكفي واحد إلا مع تقويم (وأجرته وتسمى القسامة بضم القاف على

الشركاء (على قدر الأملاك) ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعضهم باستئجاره وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته (فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة) لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه (وكيف اقترعوا جاز) بالحصا أو غيره وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم ومن ادعا غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالفا ونقضت ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ

باب الدعاوي والبينات

+ الدعوى لغة الطلب قال تعالى ﴿ ولهم ما يدعون ﴾ أي يطلبون واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يده غيره أو ذمته والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر و (المدعي من إذا سكت) عن الدعوى (ترك) فهو المطالب (والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك) فهو المطالب

(ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) و هو ا لحر المكلف الرشيد سوى إنكار سقيه فيما يؤا خذ به لو أ قر به كطلاق وحد (وإذا تداعيا عينا) أي ادعى كل منهما أنها له وهي (بيد أحدهما فهي له) أي فالعين لمن هي بيده (مع يمينه إلا أن يكون له بينة) ويقيمها (فلا يحلف) معها اكتفاء بها (وإن أقام كل واحد) منهما (بينة أنها) أي العين المدعى بها (له قضي) بها (للخارج ببينته ولغت بينة الداخل) لحديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه أحمد ومسلم ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه الترمذي وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها

ولهما فلهما وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده

27

ج ٣ - ص ٤١٤

+ واحدتها شهادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت (وتحمل الشهادة في غير حق الله) تعالى (فرض كفاية) فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين و (إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه) وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال ابن عباس وغيره المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وأداؤها) أي أداء الشهادة (فرض عين على من تحملها متى دعي إليها) لقوله تعالى ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ و محل وجوبها إن (قدر) على أدائها (بلا ضرر) يلحقه (في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله) وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته لقوله تعالى ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾

وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر (ولا يحل كتمانها) أي كتمان الشهادة لما تقدم فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال أحلف بدلي أثم ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها (ولا) يحل (أن يشهد) أحد (إلا بما يعلمه) لقوله ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال في جامعه والعلم إما (برؤية أو سماع) من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد فيلزمه

أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل (أو) سماع ب (استفاضة فيما يتعذر علمه) غالبا (بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح) عقده

ودوامه (ووقف ونحوها) كعتق وخلع وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم (ومن شهد ب) عقد (نكاح أو غيره من العقود فلا بد) في صحة شهادته به (من ذكر شروطه) لاختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا (وإن شهد برضاع) ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه (أو) شهد (بسرقة) ذكر المسروق منه

والنصاب والحرز وصفتها (أو) شهد ب (شرب) خمر وصفه (أو) شهد ب (قذف فإنه يصفه) بأن يقول أشهد قال له يا زاني أو يالوطي ونحوه (ويصف الزنا) إذا شهد به (بكر الزمان والمكان) الذي وقع فيه الزنا (و) ذكر (المزني بها) وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها (ويذكر) الشاهد (ما يعتبر للحكم ويختلف) الحكم (به في الكل) أي في كل ما يشهد فيه ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا %

1 فصل في شروط الشهادة

+ وشروط من تقبل شهادته ستة أحدها (البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان) مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض (الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل) الشهادة (ممن يختنق أحيانا) إذا تحمل وأدى (في حال إفاقته) لأنها شهادة من عاقل (الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته) لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين (إلا إذا أدها) الأخرس (بخطه) فتقبل (الرابع الإسلام) لقوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في

سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما (الخامس الحفظ) فلا تقبل من مغفل ولا معروف بكثرة سهو وغلط لأنه لاتحصل الثقة بقوله (السادس العدالة) وهي لغه الاستقامة من العدل ضد الجور وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله (ويعتبر لها) أي للعدالة (شيئان) أحداهما (الصلاح في الدين وهو) نوعان أحداهما (أداء الفرائض) أي الصلوات الخمس والجمعة (بسننها الراتبة) فلا تقبل ممن دوام على تركها لأن تهاونه بالسنن يدل على

عدم محافظته على أسباب دينه وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج (و) الثاني (اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة) والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتم وشهادة الزور وعقوق الوالدين والصغيرة ما دون من المحرمات كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء الأجانب

على وجه التلذذ به والنظر المحرم (فلا تقبل شهادة فاسق) بفعل كزان وديوث أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ويكفر مجتهدهم الدعاية

ومن أخذ بالرخص فسق (الثاني) مما يعتبر للعدالة (استعمال المروءة) أي الإنسانية (وهو) أي استعمال المروءة (فعل ما يجمله ويزينه) عادة كالسخاء وحسن الخلق و حسن المجاورة (واجتناب ما يدنسه ويشينه) عادة من الأمور الدنية المزرية به فلا شهادة لمصانع ومتمسخر ورقاص

ومغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه ولا لمن يأكل بالسوق إلا

شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه (ومتى زالت الموانع) من الشهادة (فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم) بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال

باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك

+ (لاتقبل شهادة عمودي النسب) وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا (بعضهم لبعض) كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القراب وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين لصاحبه) كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق وشهادتها له لقوة الوصلة (وتقبل) الشهادة (عليهم) فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت

عليه قبلت إلا على زوجته بزنا (ولا) تقبل شهادة (من يجر إلى نفسه نفعا) كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل وتقبل له بدينه في مرضه (أو يدفع عنها) أي

عن نفسه بشهادته (ضررا) كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه (ولا) تقبل شهادة (عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه) والمجروح على الجارح ونحوه (ومن سره مساءة

شخص أو غمه فرحه فهو عدوه) والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العدواة %

1 فصل في عدد الشهود

+ (ولا يقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا لقوله تعالى ﴿ لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ﴾ الآية (ويكفي) في الشهادة (على من أتى بهيمة رجلان) لأن موجبه التعزير ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال (ويقبل في بقية الحدود) كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق (و) في (القصاص) رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة (وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا فيه رجلان) دون النساء (ويقبل في المال وملا يقصد به) المال (كالبيع والأجل والخيار فيه) أي في البيع (ونحوه) كالقرض والرهن والغضب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه (رجلان أو رجل وامرأتان) لقوله تعالى فإن كنكاح وطلاق ورجعة

وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه) في غير مال (يقبل لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق الآيه يدل على اختصاص ذلك بالأموال (أو رجل ويمين المدعي) لقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد وغيره ويجب تقديم الشهادة عليه لا بامرأتين ويمين ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره فإن لم يتعذر فإثنان (وما لا

يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال) أي صراخ المولود عند الولادة (ونحوه) كالرتق والقرن والفعل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لايحضره الرجال (ويقبل فيه شهادة امرأة عدل) لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الرضاع شهادة أمرأة واحدة (والرجل فيه كالمرأة) وأولى لكماله (ومن أتى برجل وامرأتين أو) أتى ب (شاهد ويمين) أي حلفه (فيما يوجب القود لم يثبت به) أي بما ذكر (قود ولا مال) لأن القتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا إن الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره فلو أوجبنا بذلك الدية أو جبنا معينا بدون اختياره (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين (في سرقة ثبت المال) لكمال بينته (دون القطع) لعدم كمال بينته (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين (في) دعوى (خلع) امرأته على عوض سماه (ثبت له العوض) لأن بينته تامة فيه (وتثبت البينونة بمجرد دعواه) لإقرار على نفسه وإن ادعته لم يقبل فيه إلا رجلان 478 %

2 فصل في الشهادة على الشهادة

+ (ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق فيه كتاب القاضي إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات (ولا يحكم) الحاكم (بها) أي بالشهادة على الشهادة (إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر) أو خوف من سلطان أو غيره لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم

ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعين فرع الأصل (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول) شاهد الأصل للفرع (أشهد على شهادتي بكذا أو) أشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه وإن لم يسترعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بأذنه إلا أن (يسمعه يقر بها) أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم (أو) سمعه (يعزوها) أي يعزو شهادته (إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه (فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا كالاسترعاء ويؤديها الفرع بصفه تحمله وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه لا تعديل شاهد لرفيقه (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض) الحكم لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء (ويلزمهم الضمان) أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما

كان أو تالفا لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه (دون من زكاهم) فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى (وإن حكم) القاضي (بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم) الشاهد (المال كله) لأن الشاهد حجة الدعوى لأن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه وإنما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا حكم ولا ضمان وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود

باب اليمن في الدعاوي

+ أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا (لايستحلف) منكر (في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر (ولا في حدود الله) تعالى لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره (ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه (إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق) كدعوى رق لقيط (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب والقود والقذف) فلا

يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالمنكول ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفواعلى نفي العلم فإن نكلو قضي عليهم ومن توجب عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة (واليمين المشروعة) هي (اليمين بالله) تعالى فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق قال والله ما أردت إلا واحدة (ولا تغلظ) اليمين (إلا فيما له الخطر) كجناية لاتوجب قودا وعتق ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها وإن أبى الحالف

كتاب الإقرار

+ وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء و (يصح) الإقرار (من مكلف) لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح في قدر مأذن له فيه (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه إقرار بمال (ولا يصح) الإقرار (من مكره) هذا محترز قوله مختار إلا أن يقر بغير

ما أكره عليه كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار ويصح من سكران ومن أخرس باشارة معلومة ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه وتقدم بينة إكراه

ج ٣ - ص ٤٤٠

على طواعية (وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا و لا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون (ومن أقر في مرضه) ولو مخوفا ومات فيه (بشيء فكإقراره في صحته) لعدم تهمته فيه

(إلا في إقراره) أي إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره بأن يقول له علي كذا أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجارة (وإن أقر) المريض (لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجيه لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه (ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده (وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته لأنه كان متهما (لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث (وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه مع وجود ابنه (أو أعطاء) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء (وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذ ذاك ومسألة العطية ذكرها في الترغيب و الصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية لم يؤ خذ به إلا بعد عتقه إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف أخذ به في الحال (وإن أقرب امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح

ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لايقبل وهو رواية والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين فإن جهل فقول ولي فإن جهله الولي فسخا ولا ترجيح بيد (وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره (أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن بزوجها (صح) إقراره به لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما ثم إن صدقته إذا بلغت قبل (وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه) ولو أسقط به وارثا معروفا لأنه غير متهم في إقراره لأنه لاحق للوارث في الحال (فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر وأن لاينفي به نسبا معروفا وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من

تصديقه (وإن ادعى) إنسان (على شخص) مكلف (بشيء فصدقه صح) تصديقه وأخذ به لحديث لاعذر لمن أقر والإقرار يصح بكل ما أدى معناه كصدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك أو أنا مقر فقط أو أخذها أو اتزنها أو قبضها أو أحرزها ونحوه لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا ونحوه %

1 فصل

+ (إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه (وإن قال) له علي ألف وقضيته أو برئت منه أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولايكون مقرا فإذا حلف خلي سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرها فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه ويصح

استثناء النصف فأقل في الإقرار فله علي عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان أكثرها (وإن قال له علي مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا) أي معيبة (أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة) لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال وما أتى به بعد سكوته لا يتلفت إليه لأنه يرفع به حقا لزمه (وإن أقر بدين مؤجل) بأن قال بكلام متصل له علي مائة مؤجلة إلى كذا ولو قال ثمن مبيع ونحوه (فأنكر المقر

له الأجل) وقال هي حالة (فقول المقر مع يمينه) في تأجيلة لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك وكذا لو قال له علي ألف مغشوشة أو سود لزمه كما أقر (ولو أقر أنه وهب) وأقبض (أو) أقر أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها (ثم أنكر) المقر الإقباض أو (القبض ولم يجحد الإقرار) الصادر منه (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك (فله ذلك) أي تحليفه فإن نكل حلف هو وحكم له لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله (وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر) البائع أو الواهب أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق (كان لغيره لم يقبل قوله) لأنه إقرارعلى غيره (ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهبة والعتق (ولزمته غرامته) للمقر له لأنه فوته عليه (وإن قال لم يكن) ما بعته أو وهبته ونحوه (ملكي ثم ملكته بعد) البيع ونحوه (وأقام بينة) بما قاله (قبلت) بينته

(إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو) قال (إنه قبض ثمن ملكه) فإن قال ذلك (لم يقبل منه) بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو قال هو لزيد بل لعمرو فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو %

1 فصل في الإقرار بالمجمل

+ وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر (إذا قال) إنسان (له) أي لزيد مثلا (علي شيء أو) قال له علي (كذا) أو كذا و كذا أو كذا وكذا أو له علي شيء وشيء (قيل له) أي للمقر (فسره) أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه (فإن فسره بحق شفعة أو) فسره (بأقل مال قبل) تفسيره إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لايدعي شيئا فيبطل إقراره (وإن فسره) أي فسر ما أقر به مجملا (بميتة أو خمر) أو كلب لا يقتنى (أو) بما لايتمول (كقشر جوزة) أو حبة بر أو رد

سلام أو تشميت عاطس ونحوه (لم يقبل) منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر (ويقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه) لوجوب رده (أوحد قذف) لأنه حق آدمي كما مر وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم وإن مات قبل

تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد (وإن قال) إنسان عن إنسان (له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه) أي إلى المقر لأنه أعلم بما أراده (فإن فسره بجنس واحد) من ذهب أو فضه أو غيرهما (أو) فسره (بأجناس قبل منه) ذلك لأن لفظه يحتمله وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل وله علي ألف ودرهم أو وثوب ونحوه أو دينار وألف أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم أو ألف إلا درهما فالمجمل من جنس المفسر معه وله في هذا العبد شرك أو شركة أو هو لي وله أو شركة بينا أو له فيه سهم رجع في

تفسير حصة الشريك إلى المقر وله علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف (وإذا قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) لعدم دخول الغايه وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد أي الواحد والإثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانيه والتسعة والعشرة لزمه خمسة وخمسون وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه درهم أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم بل درهمان لزمه دراهمان (وإن قال) إنسان عن آخر (له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما) ويرجع في تعينه إليه لأن (أو) لأحد الشيئين وإن قال له درهم بل دينار لزماه (وإن قال) المقر (له علي تمر في جراب أو) قال له علي (سكجين في قراب أو) قال له (فص في خاتم ونحوه) كله ثوب في منديل أو عبد عليه

عمامة أو دابة عليها سرج أو زيت في زق (فهو مقر بالأول) دون الثاني وكذا لو قال له عمامة على عبد أو فرس مسرجة أو سيف في قراب ونحوه وإن قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله وإقراره بشجر أو بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان